

xxvi), pero también aquí cabe recordar que cuando una cosa de propiedad del testador es dejada a alguien con la fórmula *do lego* (por ejemplo: *L. Titio hominem Stichum do lego*), la cosa legada pasa del testador al legatario directamente, y el legatario puede reivindicarla contra cualquiera, heredero o extraño, que la posea.

En cambio, se hallan ciertamente fuera del tema que nos ocupa los casos en que los bienes pasan en bloque de su titular a un sucesor (universal, cfr. p. 40): así la adquisición de la propiedad civil como consecuencia de la herencia o *adrogatio* o *conventio in manum*, de la propiedad pretoria como consecuencia de la *agnitio bonorum possessionis* o de la *bonorum emptio*.

9) *In iure cessio*. — Es quizá el más antiguo de los modos de transmisión reconocido por el derecho civil (menos antiguo, en la práctica, que la entrega manual de la cosa, la cual, no obstante, debió ser en los orígenes más bien institución social que jurídica); y, sin embargo, no es un medio inventado con ese fin, sino una aplicación de los principios y de las formas del proceso de propiedad. Se finge querer instaurar una *litis* de propiedad mediante la *legis actio sacramenti in rem* (p. 130): adquirente y transmitente comparecen ante el tribunal del magistrado, con la cosa o con la parte que la represente, como si fueran litigantes. El adquirente cumple también la ceremonia de la *vindicatio*, pronunciando la fórmula *ago hanc rem (hunc hominem, hunc fundum, etc.)*, *meam esse ex iure Quiritium*, y tocando la cosa con la varilla que es el símbolo del dominio. El transmitente, que podría pronunciar la misma fórmula (*contravindicatio*) con seguridad de vencer, no la pronuncia: al contrario, interrogado por el pretor *an contra vindicet*, responde negativamente o guarda silencio. De ahí el nombre de la institución, en la cual *in iure* significa, como en tantas otras locuciones, "ante el tribunal del magistrado", *cessio* el acto de retirarse. Como en todos los otros casos en que la *litis* se evita por abandono por parte de uno de los contendientes, el magistrado debe considerar vencedor en la causa al reivindicante *addicere ei rem*: así éste es reconocido como propietario²⁰.

²⁰ Sobre las dificultades a que en los detalles da lugar la construcción como proceso ficticio, cfr. MITTELS, *Römisches Privatrecht*, I, ps. 276 y ss.; NABER, *Studi Perozzi*, ps. 341 y ss.; y en forma paradójica WLASSAK, "Rev. Fundac. Savigny", 28, 1907, ps. 75 y ss., quien niega directamente a la *in i. c.* la estructura procesal (en sentido análogo, LÉVY-BRUHL, *Quelques problèmes du très ancien droit romain*, París, 1934, ps. 144 y ss.).

Tal como lo hemos descrito, y con las palabras que hemos puesto en boca del adquirente, la institución es propia de la adquisición de la propiedad, pero en su estructura fundamental representa, en cambio, un tipo que puede ser objeto de tantas aplicaciones como sean las acciones *in rem*; por eso, en la época clásica, cuando las *legis actiones* no tenían ya aplicación en el procedimiento contencioso, su nombre fué usado para designar los actos solemnes conformes al modelo descrito²¹.

En los primeros siglos de la era imperial, la *in iure cessio* es, quizá, menos usada para la propiedad que para los otros derechos recordados; pero las fuentes atestiguan que también en materia de propiedad, cuando por la naturaleza de la cosa transmitida resultaba inadecuado el recurso en la forma más materialista de la *mancipatio*, se usaba *in iure cedere*; por ejemplo, para trasferir cuotas de condominio, la nuda propiedad (*proprietas*) de cosas sujetas al usufructo de otro, etc.

Solamente en el derecho posclásico la *in iure cessio* desaparece, en esta aplicación como en todas las otras, porque las nuevas formas procesales hacen desaparecer hasta el recuerdo de la *legis actio*; porque la *traditio* en sus nuevas realizaciones basta ahora para transmitir cualquier cosa corporal; porque, en fin, en esta época desaparece todo lo que queda del antiguo formalismo romano. En los pasajes recogidos en la compilación justiniana las palabras *in iure* fueron siempre suprimidas, y el verbo *cedere* permaneció con el significado transitivo y anodino que todavía conserva.

10) *Mancipatio* o *mancipium*. — Se remonta hasta la época en que no existía todavía la moneda acuñada (*pecunia numerata*, contante), sino el bronce no acuñado (*aes rude*) que debía pesarse vez por vez; y consistía, cuando surgió, en una compraventa real, cambio inmediato de cosa contra precio. Comprador y vendedor intervenían en ella, en los orígenes, con la cosa (o, con más frecuencia, con un símbolo de ella); y con sus cinco testigos, ciudada-

²¹ Cfr. GAYO, II, 24; y la frase *certa legis actione* con que, en el nuevo fragmento publicado en P. S. I., XI, 1182 (leyes 31 y 32), el mismo GAYO describía el recíproco reconocimiento ficticio como hermanos coherederos. Sobre la variedad de aplicaciones, cfr. p. 90; y para las hipótesis particulares los capítulos sobre las servidumbres y usufructo (VIII, § 4), sobre la *patria potestas* (XXII), sobre la esclavitud (XXIII), sobre la tutela (XXIV), etc.

nos romanos y púberes, y un *libripens*, provisto de una balanza (*libra*) controlada por la autoridad ciudadana. El comprador, tocando la cosa, pronunciaba las palabras: "aio hanc rem meam esse ex iure Quiritium, eaque mihi empta esto hoc aere (o quizá, en esta época antiquísima, *his quindecim ponderibus aeris* o análogamente) aeneaque libra"²², y echaba entonces sobre el plato de la balanza el *aes rude* necesario para el pago. No se requería ninguna declaración de voluntad por parte del vendedor²³.

Posteriormente, la fórmula permaneció casi intacta, pero la sustancia de la institución cambió por dos órdenes de causas. Por una parte, inventado como medio de pago el dinero acuñado que se cuenta (*pecunia numerata*), la pesada del *libripens* se transforma en un mero símbolo, en tanto que, en realidad, el precio era pagado de otra manera, fuera del negocio solemne; por otra parte, las exigencias de los cambios internacionales hicieron surgir el contrato de compraventa, *iuris gentium* y consensual, fuente de las obligaciones de transmitir recíprocamente la cosa y el precio. Así la *mancipatio* se transformó en un negocio abstracto de transmisión de la propiedad sobre las *res Mancipi*. Es a esta segunda función de la institución que se refiere la definición que de ella da GAYO (I, 119) cuando la llama *imaginaria venditio*: *venditio* porque todavía se aparenta pagar; *imaginaria* porque la causa por la cual se transmite la propiedad puede ser cualquier otra que la venta. En este período, el *libripens* lleva consigo, además de la balanza, también una varita de cobre (*raudusculum*); y después que el *mancipio accipiens* (adquirente) ha pronunciado la conocida fórmula, se

²² Veremos a propósito de la *solutio per aes et libram* (cap. XVIII, § 1) una frase ulterior que ha formado quizá parte del más antiguo formulario.

²³ Que la institución así descrita sea antigua, es evidente; pero no creo que sea aceptable la opinión de quien, como PEROZZI, la considera precívica. No me ocupo del argumento que se podría sacar en contrario de la querida correspondencia de los cinco testigos con las cinco clases de la constitución serviana, pues esta correspondencia tendría necesidad, ella misma, de demostración. Pero es cierto que tampoco el *aes rude* se remonta, como medio de pago, hasta una edad anterior a aquella a que la tradición refiere la fundación de la ciudad; y por otra parte, la primera parte de la fórmula pronunciada por el *mancipio accipiens* está tan poco dentro de lugar en un acto de adquisición, y tan conforme a la *vindicatio*, que se presenta espontánea la idea de una imitación de la *in iure cessio*, a la cual, en consecuencia, la *mancipatio* sería posterior. Esta opinión es, sin embargo, ampliamente combatida, y por lo que a mí respecta, confieso que estoy ahora mucho menos seguro de lo que lo estuviera en otros tiempos.

la entrega diciendo: *raudusculo libram ferito*; el *accipiens* obedece, golpeando con la varita la balanza. Pero, a los fines que en seguida se indicarán, correspondía que el *mancipio accipiens* manifestase en su declaración el precio a que adquiriría: si no tenía que pagarlo (tratándose, por ejemplo, de donación), afirmaba comprar por un solo sestercio, *sestertio nummo uno*²⁴.

También la *mancipatio*, como la *in iure cessio*, representa en el antiguo mundo romano un tipo de negocio de infinitas aplicaciones (p. 90), algunas de las cuales tienen su raíz en la época en que el acto era una verdadera venta, mientras otras surgieron solamente en el período de la *imaginaria venditio*. Antiquísimas parecen ser, y no como ficticias sino como correspondientes a la precisa intención de las partes, la venta de la hija de familia como esposa y del hijo *in mancipium*, que volveremos a encontrar en los capítulos XXI y XXII. Con el nombre de *nexum*, quizá equivalente en los orígenes a *mancipium* o *mancipatio*, se designó con preferencia la venta que alguien hiciese de sí mismo o de los sujetos a su potestad con fines de garantía de una obligación (cfr. cap. XIV, § 3); con el nombre de *fiducia* se designó la *mancipatio* de una cosa con análogo fin de garantía (cap. X). También el testamento fué en un estadio muy importante de su desarrollo una *mancipatio familiae*, es decir, venta del patrimonio a persona de confianza (cap. XXV).

Para todos estos casos, y para otros que se recordarán en su lugar, era necesario que la declaración del *accipiens* se fuera modificando, o que el *mancipio dans* (enajenante), personaje ordinariamente mudo, pronunciase él también frases, llamadas *nuncupationes* e indicadoras del fin del acto. Por ejemplo, en la *fiducia*, el adquirente debe haber dicho: "*aio hanc rem meam esse ex iure Quiritium fiduciae causa*"; y para la *mancipatio familiae* con fines testamentarios nos es transmitida toda una declaración que el testador (*mancipio dans*) pronunciaba después que el *familiae emptor* había recitado aquella con que imitaba el formulario de la *mancipatio*.

Cláusulas semejantes se introdujeron también en la *mancipación* destinada a su fin fundamental de transmisión de la propiedad; por ejemplo, se usó incluir en los formularios la mención de las servidumbres que gravaban el fundo vendido o la declara-

²⁴ Cfr., por último, PUGLIESE, *Simulazione*, ps. 66 y ss.

ción de su inexistencia; y se usó también constituir por vía de *deductio* de la *mancipatio*, derechos de servidumbre o de usufructo (por ejemplo, "aio hunc fundum meum esse deducto usufructu, deducto aquae haustu, deducta via, isque etc.").

Para que la *mancipatio* haga propietario al *accipiens*, es necesario que sea actualmente *dominus ex iure Quiritium* el *mancipio dans*. Pesa por eso sobre el *mancipio dans*, siempre que el precio se haya pagado efectivamente, la *obligatio auctoritatis*, la cual importa que intentándose por otro una *rei vindicatio* contra el adquirente, éste pueda llamar a la causa al trasmittente; el llamado tiene ante todo la obligación de sustituir en el juicio a su derechohabiente (de allí los nombres de *auctor* y de *auctoritas*), pero si no cumple con esta obligación, o si, aun haciendo cuanto está de su parte, pierde la *litis*, está obligado a restituir al adquirente el doble del precio a su tiempo percibido. Es ésta la forma más antigua de la garantía por evicción, que estudiaremos al tratar de la compraventa (cap. xiv, § 4); la garantía se debe, en general, hasta que en favor del adquirente se cumpla la usucapión (cfr. p. 231, n. 31). Igual obligación incumbía al *mancipio dans* si un vecino reivindicaba contra el adquirente una servidumbre no declarada en la *mancipatio*; salvo que aquí, en caso de ser vencido, el vendedor pagaba sólo el doble de la disminución del valor que el fundo sufría por aquella servidumbre.

Si el *mancipio dans* ha indicado la medida del fundo que trasmite a título oneroso, y ésta resulta inexacta, al *accipiens* le corresponde contra él una acción de *modo agri*, dirigida al pago del doble del valor de esa diferencia.

Así construido y adaptado para innumerables aplicaciones, el *gestum per aes et libram* permaneció en pleno vigor durante toda la época clásica, y aun cuando, por haberse encontrado modos más ágiles y adecuados para alcanzar los propósitos de las partes, fué decayendo en casi todos los otros campos, su función de acto de transmisión de la propiedad sobre las *res Mancipi* permaneció intacta, y documentos del siglo II nos muestran su aplicación en todas partes del Imperio. Si desde la época republicana se usó redactar un documento escrito, sellado por las partes y por testigos, éste servía solamente para la prueba de la *mancipatio* realizada pero perdía todo valor si de otra manera se demostraba que se habían omitido las palabras y los gestos rituales. Pero

cuando la *mancipatio* fué practicada más o menos abusivamente también en ambientes no romanos (como en los documentos de Transilvania²⁵), y más ampliamente después que todos los provinciales se hicieron romanos (ps. 63 y ss.), la atestación documental fué sustituyendo la efectiva ejecución de la *mancipatio*: el documento tendía a trasformarse, del mismo modo que veremos al estudiar la tradición, de medio de prueba en forma por sí suficiente. Por otra parte, el prevalecer de la propiedad provincial sobre la quiritaria, de los fundos provinciales, *nec Mancipi*, sobre los itálicos, contribuyó a la lenta decadencia de la institución, que en el derecho justiniano termina desapareciendo conjuntamente con la distinción entre *res Mancipi* y *nec Mancipi*. Esto no impide que la *mancipatio* sobreviva, como una cláusula que los disponentes repiten sin correspondencia alguna con la realidad, también en documentos italianos del medievo.

11) *Traditio*. — Es quizá, en la costumbre social, el modo más antiguo de trasmisión; y también es el más natural, consistiendo en la pura y simple entrega de la cosa por el enajenante al adquirente. Hecha la salvedad de la categoría de las cosas *pretiosiores*, susceptibles solamente de *mancipatio* y de *in iure cessio*, la tradición se nos presenta en la época histórica como el modo de trasmisión específico de las *res nec Mancipi*.

La simple entrega en que este negocio consiste, es por su naturaleza tal como para poder servir también a fines mucho más modestos; para que la propiedad se trasmita es necesario, por lo mismo, que en torno a la entrega haya todo un concurso de circunstancias que legitimen el pasaje de la cosa del *tradens* al *accipiens*. Tales circunstancias son:

a) que la cosa esté en propiedad del tradente, o de cualquier modo dentro de su poder de disposición;

β) la voluntad del tradente de desprenderse de la cosa para transferirla a la contraparte, y la voluntad del *accipiens* de tomarla para sí²⁶;

²⁵ Véase los en mis *Negotia*, n°. 87 a 90.

²⁶ Sustituyo con esta fórmula, de carácter más bien económico que jurídico, tomada de LENEL, "Jahrbücher für die Dogmatik" ["Anales para la Dogmática"], 19, 1881, ps. 173 y ss., la referencia que en las primeras ediciones hacía a la voluntad de transmitir y de adquirir la propiedad; esto con relación a aquel vínculo entre la voluntad de las partes y el negocio jurídico, de que se ha hablado en la p. 88. BETTI, *Studi Riccobono*, IV,

γ) una *iusta causa traditionis*, es decir un complejo jurídico del cual forme parte la entrega, y que el derecho objetivo considere razón suficiente para la transmisión de la propiedad. Se tendrá, por ejemplo, una *iusta causa credendi* si yo entrego a alguien una suma de dinero para que se sirva de ella y me restituya otro tanto en determinado momento (*mutuo*); una *iusta causa solvendi* si este deudor mío, u otro cualquiera obligado a la entrega de cosas *nec mancipi*, paga la deuda; una *iusta causa dotis dandae* si, no estando comprometido por una precedente promesa²⁷, entrego a mi yerno bienes a título de dote. El depósito, en cambio, no es *causa traditionis*, porque la estructura del contrato importa que la cosa depositada continúe en propiedad del depositante; la donación entre cónyuges, que el derecho romano prohíbe, no es una *causa iusta*.

En cuanto a la entrega en sí misma, el derecho antiguo quiere que ella sea material, pero la materialidad es, naturalmente, diversa de cosa a cosa: un mueble se puede entregar pasándolo de mano a mano; en el fundo es necesario entrar, pero siempre se ha excluido la necesidad de tomar posesión terrón por terrón (*omnes glebas circumambulare*). Y probablemente ya el derecho clásico ha admitido que a veces pudieran equivaler a la entrega material otros modos de actuación del poder del *accipiens* sobre la cosa. Tales son, principalmente:

α) la entrega de las llaves de un depósito con el fin de hacer tradición de las mercaderías que hay en él (llamada *traditio symbolica* por la ciencia medieval);

β) la indicación de un fundo de lo alto de una torre o de una colina desde donde se pueda dominarlo, como sustitutivo de la entrega del fundo mismo (llamada *traditio longa manu*);

γ) la transformación del estado de ánimo de las partes con relación a la cosa, en el sentido de que quien primero la retenía en nombre de otro (por ejemplo, a título de usufructo o de arrendamiento) comience desde ahora con la conformidad de la contraparte a poseerla como propia (llamada *traditio brevi manu*);

p. 124, quería atribuir a las partes la voluntad de *disponer de la posesión*; inexactamente, porque el hombre de la calle cree que posesión y propiedad son la misma cosa, mientras que quien conoce su diversidad piensa en disponer de la posesión solamente en el caso en que no quiere o no puede transmitir o adquirir la propiedad.

²⁷ De otra manera se tendría nuevamente una *causa solvendi*.

δ) la transformación del estado de ánimo de las partes en sentido inverso, es decir, en el sentido de que quien primero poseía la cosa en nombre propio, la quiera trasferida a otro, pero continúe sin embargo reteniéndola en lugar del adquirente, como usufructuario o arrendatario (*constitutum possessorium*).

Se pretende²⁸ que, por lo menos en el derecho clásico, ciertos tipos de tradición espiritualizada, requieran siempre, sin embargo, una cierta presencia de la cosa: esto es evidente en el caso β, y aun en el de la entrega de las llaves (α) parece que los juristas exigiesen que tuviera lugar *apud horrea*; pero semejante requisito resulta inadecuado para las declaraciones de voluntad que en los casos γ y δ sustituyen a la entrega. De cualquier manera, es evidente que en el espíritu de la jurisprudencia romana los tipos descritos no tienden a eliminar la exigencia de la entrega efectiva, sino a regular ciertas situaciones en que sería ridículo pretenderla: la *traditio brevi manu* se aplica si efectivamente el *accipiens* es ya usufructuario o locatario; el *constitutum possessorium*, si efectivamente el *tradens* quiere continuar reteniendo como usufructuario o locatario la cosa a cuya propiedad renuncia.

Pero después de la celeberrima constitución caracalliana del 212, la tradición fué una de las instituciones que más tuvieron que sufrir con la lucha entre derecho imperial y derecho local. En las provincias helenísticas no existía una neta distinción entre contrato obligatorio y acto de transmisión de la propiedad; por ejemplo, la compraventa, que en los orígenes había sido un cambio inmediato de cosa contra precio, a la par de la *mancipatio* romana, había terminado por incorporarse a un documento, con el cual el vendedor reconocía el pasaje de la propiedad como un efecto inmediato de la recepción del precio. No había, en consecuencia, ni una obligación de trasferir la cosa, como la que asumía el comprador romano, ni una entrega material de ella. Y esto que se dice de la compraventa se podría repetir de todo otro negocio que tuviera por mira la trasferencia de la propiedad. De este predo-

²⁸ RICCOBONO, *Traditio ficta*, en la "Rev. Fundac. Savigny", 33 (1912), ps. 259 y ss.; 34 (1913), ps. 159 y ss.; de cuyo estudio me valgo ampliamente también para cuanto sigue, en los límites en que con él concuerdo. Para el derecho justinianeo, me sirvo también de los textos recopilados en von DRUFFEL, *Papirologische Studien zum byzantinischen Urkundenwesen...* [Estudios papirológicos sobre los documentos bizantinos...], Monaco, 1915, ps. 62 y ss.

minio de la escritura, por la cual la voluntad cristalizada en ella no tenía necesidad de tomar cuerpo en actos materiales, derivó también la costumbre de trasferir la cosa entregando simplemente los documentos probatorios de la legítima adquisición hecha en su tiempo por el actual trasmitente.

No todas las fases de la lucha entre la concepción romana y la provincial se pueden seguir; sobre todo porque muchas veces cambió, no el medio técnico, sino el espíritu con que se lo empleaba. Esto es visible, en particular, en lo que se refiere al constituto posesorio; si los juristas romanos lo conocieron, ellos lo practicaron, como hemos dicho, sólo cuando la intención de las partes era que el propietario actual se hiciese efectivamente usufructuario o locatario; en el mundo posclásico, en cambio, se usó ampliamente constituir, para todo acto de venta o de donación, un usufructo de duración mínima, cuyo solo fin era evitar la tradición material. Son característicos, a este propósito, los papiros raveneses editados por Marini, de los cuales los más antiguos son de época prejustiniana.

Otras veces la lucha se presenta más áspera y se conocen mejor sus fases. Muchos rescriptos de viejos emperadores, reproducidos en el Código justiniano, confirman la ineptitud de la tradición de los documentos referentes a la cosa para sustituir la tradición de la cosa misma; pero hay uno (C. 8, 53, 1) en el cual se afirma lo contrario, y es probable que los compiladores del siglo vi lo hayan así reelaborado. Igualmente característico es el cotejo entre las constituciones genuinas del tiempo de Constantino a Teodosio II, reproducidas en el Código teodosiano, y la nueva edición que de ellas da el Código justiniano; en los textos genuinos la exigencia de la *traditio* material está netamente señalada, mientras en la revisión posterior se eliminaron las frases a ella relativas. El hecho de que todas las interpolaciones recordadas se refieran a materia de donación, es un signo de que el desarrollo es todavía parcial; pero es ya característico cuán necesario se consideraba otorgar a la donación un particular favor, liberándola de la exigencia de aquel acto de transmisión de la cosa, que en el pensamiento romano había representado una necesidad intuitiva. Igual significado tiene la exoneración de la tradición para las adquisiciones de las iglesias, de las obras pías y de las ciudades (C. 1, 2, 22, de JUSTINIANO).

A una innovación radical que aboliese la tradición, no llegaron ni siquiera los últimos emperadores. Mediadores también aquí entre lo viejo y lo nuevo, se han limitado a las reformas parciales ya indicadas, y en muchos otros casos han confirmado la exigencia de una *corporalis traditio*. Sin embargo, quien sepa leer en las constituciones del Código y en los edictos de los prefectos del pretorio (comenzando por la época de Constantino) siente que estas palabras suenan a falso. El mismo adjetivo *corporalis*, del cual ningún clásico habría sentido la necesidad, muestra cómo el ambiente estaba ahora orientado hacia una *tradición no corporal*; y por lo demás, la tradición aparece en ciertas constituciones tan malamente insinuada en un desarrollo totalmente documental, como para deber necesariamente ahogarse en su aplicación. Léase, por ejemplo, la constitución de TEODOSIO, ARCADIO y HONORIO en C. 4, 3, 1 § 2: "Quod si praedia rustica vel urbana placitum continebit, scriptura, quae ea in alium transferat, emittatur, sequatur traditio corporalis, et rem fuisse completam gesta testentur"; la que trasfiere la propiedad del fundo es, en conjunto, la *scriptura*, el documento, y la declaración es tanto más preciosa si se piensa que la frase debe más bien habersele escapado a los emperadores que ser querida; es cierto que debe seguir, según el texto, la tradición corporal, pero cualquiera ve que la única cosa esencial es la mención a hacerse en las actas (*gesta*) por la autoridad judicial.

En suma, el derecho justiniano distingue todavía, igual que el derecho clásico, el contrato como fuente de obligación y el acto de transmisión de la cosa; pero este acto, que para las cosas de menor importancia ha continuado siempre cumpliéndose en la forma elemental de la entrega de mano a mano, para las cosas que suelen transferirse ante notario se ha ido espiritualizando en la entrega de los documentos, ya reduciéndose a la pura mención de una *traditio* jamás sucedida, ya trasformándose en un fingido constituto posesorio. Posteriormente, una larga evolución que parte de estas formas de *traditio ficta* y se cumple a través del derecho intermedio, ha conducido al actual traspaso de la propiedad mediante el consentimiento, tal cual está sancionado en el art. 1376, Cód. Civ. italiano (cfr. p. 219).

Donde el derecho posclásico, y el justiniano especialmente, innova con plena conciencia, es en el hecho de rodear la tradición inmobiliaria de formalidades particulares accesorias en tutela de

las partes y de los terceros. Desde este punto de vista, el derecho romano clásico nos presenta, con un obsequio a la tradición que no puede dejar de sorprender, la persistencia de un sistema que solamente podía ser suficiente para las exigencias de una aldea de campesinos como era la Roma primitiva. La *mancipatio* es pública porque se realiza en el mercado y en presencia de cinco testigos, la *in iure cessio* porque se realiza en el tribunal; pero esta publicidad no podía garantizar a nadie en un ambiente vasto como el de la Italia de Augusto o como el *orbis Romanus* de Caracalla²⁹. El derecho justiniano fija para los actos de transmisión de los inmuebles el requisito de la *scriptura* (documento escrito), y favorece de todos modos la práctica, introducida en los últimos siglos, de que tales trasferencias sean registradas en los *gesta*. Estos eran procesos verbales redactados en las cancillerías de los tribunales, que de la función originaria de documentar el desarrollo de los procesos habían sacado también la de dar forma solemne a las declaraciones de los particulares³⁰: desde el siglo IV la legislación imperial reconoció oficialmente tal práctica, sobre todo cuando los protocolos se redactasen ante los presidentes de las provincias. Más tarde, la competencia para recoger tales declaraciones se extendió a funcionarios menores, especialmente a los *curatores rerum publicarum* y a otros magistrados municipales, en la época justiniana el funcionario a quien habitualmente se recurre es el *defensor civitatis*, y aun faltando una norma general que imponga la *insinuatio* (salvo el caso de las donaciones), la práctica de las diversas provincias la exige.

12) *Usucapio y longi temporis praescriptio*. — El acto de adquisición de la propiedad puede ser, como varias veces se ha señalado, de tal manera defectuoso que no pueda producir su efecto: o porque cosas cuya transmisión requiere particulares formalidades (en Roma, las *res Mancipi*) hayan sido transmitidas con acto no

²⁹ En ciertas provincias, y especialmente en Egipto, los romanos han impuesto registros fundiarios (βιβλιοθήκαι τῶν ἐγκτήσεων), que permitían a los interesados establecer (dentro de ciertos límites) si el enajenante de un inmueble tenía derecho a disponer de él y si la propiedad estaba limitada por derechos reales. Pero era una ventaja refleja; en tanto que el verdadero fin de la institución consistía probablemente en verificar la capacidad contributiva de los individuos, especialmente para la repartición de las onerosísimas prestaciones gratuitas a la administración pública (liturgias).

³⁰ Cfr. sobre el tema BICKERMANN, *Testificatio actorum*, en "Aegyptus", 13, 1933, ps. 333 y ss.

solemne (*traditio*), o porque el que las ha transmitido no fuese propietario. Ahora bien; puesto que la cadena que liga entre sí a todos los sucesivos adquirentes de una cosa (y de un inmueble especialmente) puede ser larguísima, y puesto que el vicio ínsito a uno cualquiera de los traspasos alcanza a todos los sucesivos, casi nadie podría afirmar y demostrar ser propietario; en este sentido, los juristas medievales decían que la prueba del dominio es una *probatio diabolica*. De aquí la necesidad de establecer un límite de tiempo, transcurrido el cual quien ha adquirido en circunstancias merecedoras de protección, continuando luego en posesión de la cosa, se hace propietario de ella sin otro requisito; tal forma de adquisición, integrando las deficiencias de cualquier precedente acto de transmisión, redunda también en beneficio de los adquirentes sucesivos, para los cuales la obligación de probar la legitimidad de los precedentes traspasos se detiene en el punto donde se demuestre que alguno ha gozado de la cosa por el tiempo suficiente.

Este modo de adquisición recibía antiguamente el nombre de *usus* o *usucapio*; y el término fijado por las XII Tablas era de dos años para los fundos (es decir, en general, para los inmuebles, y quizá también para los derechos inmobiliarios) y de un año para las otras cosas, entre las cuales se consideraba comprendida, por la tendencia romana a equiparar el dominio y las potestades familiares, también la *manus* sobre la mujer casada³¹.

³¹ El texto, por cierto lingüísticamente puesto al día, que nos da Cicerón (*Top.*, 4, 23), dice: "*usus auctoritas fundi biennium est, ceterarum rerum omnium annuus est usus*". Clara es la razón de la reunión de *usus* y *auctoritas* (cfr. p. 224): tanto dura la obligación de garantía del transmitente cuanto es el tiempo necesario de la adquisición; cumplida la usucapión, el adquirente tiene un título autónomo, contra el cual se paraliza la reivindicación del tercero. Puesto que, de conformidad con los principios generales (p. 60), la usucapión no tiene lugar en favor de los extranjeros, quien vende a un forastero está obligado a la *auctoritas* sin límites de tiempo: *adversus hostem* —dicen las XII Tablas— *aeterna auctoritas*, donde no hay necesidad ni posibilidad de traducir *auctoritas* con "reivindicabilidad" (así SIBER, *Römisches Recht*, p. 83, n° 3). La interpretación por mí sostenida, es ahora defendida por DE VISSCHER, "Rev. Hist. de Dr.", 4^o serie, 16, 1937, ps. 574 y ss., aunque su doctrina general sobre la *auctoritas* ("Rev." cit., 12, 1933, ps. 617 y ss.) diverja algo de la mía; sobre el tema véase también JOERS-KUNKEL, *Römisches Recht*, ps. 134 y ss.; y en conexión con puntos de vista del todo nuevos (y en mi opinión algo arbitrarios), LEIFER, *Mancipium und auctoritas*, en "Rev. Fund. Savigny", 56, 1936, ps. 136 y ss., y LÉVY-BRUHL, *Nouvelles études sur le très ancien droit romain*, Paris, 1947, ps. 14 y ss.

A esta institución, que permanece en vigor durante toda la época clásica, se agrega, en la época de los Severos, otro medio jurídico probablemente de origen griego³². Existía en el proceso griego una institución análoga a la *exceptio romana*, llamada παραγραφή, y una de sus aplicaciones consistía en la facultad de oponer a una acción, real o personal, el trascurso de un largo período de tiempo durante el cual no se hubiese ejercido el derecho. Ahora bien; a los fundos provinciales, que como se ha visto no se tenían en propiedad civil, tampoco les era aplicable la usucapión; y pareció, en consecuencia, oportuno recurrir a la institución griega, que podía prestar servicios análogos. El nombre de παραγραφή, se tradujo con *praescriptio* (palabra ya en uso en el proceso romano, pero con otro significado: cfr. p. 151), y la *praescriptio longi temporis* comenzó a introducirse en la época indicada, primero por vía excepcional, después en amplísima escala³³.

Así definida, la *praescriptio longi temporis* tenía efectos mucho más modestos que la *usucapio*; mientras ésta hacía adquirir la propiedad quiritaria y daba, en consecuencia, al adquirente, la *rei vindicatio* contra todo poseedor, aquélla no hacía adquirir la propiedad provincial ni permitía reivindicar la cosa, sino que sólo autorizaba al poseedor para defenderse contra la acción del propietario.

Sin embargo, en aquel inmenso crisol que es el Imperio de Oriente, *usucapio* y *praescriptio* se funden, extendiéndose a la segunda la estructura propia de la primera. En el derecho justinianeo, el nombre de *usucapio* sólo se da normalmente a la adquisi-

³² Así, PARTSCH, *Die longi temporis praescriptio*, Leipzig, 1906, ps. 118 y ss.

³³ La mención más antigua se tiene en un rescripto de Septimio Severo y Caracalla referido en dos papiros, uno de Berlín y el otro de Estrasburgo; en el segundo (P. Strassb. 22 = Ricconono, *Leges*, n° 85), que es el más completo, se dice explícitamente que las disposiciones a propósito han sido dictadas para los habitantes de las provincias (περι τῶν ἐν ταῖς ἔθνεσιν οἰκούντων) y el rescripto está referido así: Μακρὰς νομῆς παραγραφή τοῖς δικαίαν αἰτίαν ἐσχηκόσι καὶ ἀνευ τινὸς ἀμφισβητήσεως ἐν τῇ νομῇ γενομένοις, πρὸς μὲν τοὺς ἐν ἄλλῃ πόλει διατρεῖσαντας ἑτῶν εἴκοσι ἀριθμῷ βοηθοῦνται (mejor, en el documento berlinés, βεβαιοῦνται), πρὸς δὲ τοὺς ἐπὶ τῆς αὐτῆς δέκα [*iustam causam habentibus et sine ulla controversia in possessione manentibus longae possessionis praescriptio adversus dominos in alia civitate degentes post viginti annos conceditur, adversus dominos in eadem civitate post decem annos*].

ción de los muebles, que se cumple en tres años; en cambio, se llama *praescriptio longi temporis* a la adquisición de los inmuebles que se cumple a los diez años *inter praesentes* (es decir, si el propietario y la cosa poseída por otro están en la misma ciudad) y a los veinte *inter absentes*.

En fin, para los casos en que la falta de los requisitos que veremos (máxime de la justa causa) hacía inaplicable tanto la *usucapio* como la prescripción normal, surgió, por un rescripto de Constantino, la *praescriptio longissimi temporis*, que se cumplía primero a los cuarenta años, después por regla a los treinta, pero a los cuarenta si era en perjuicio del Estado o de la Iglesia o de comunidades menores u obras pías; tal prescripción está excluida sólo para las cosas sustraídas violentamente³⁴.

Muy delicada es la investigación en torno al modo en que se han afirmado aquellos dos requisitos fundamentales de la usucapión clásica, que son la justa causa y la buena fe³⁵. Y quizá para el derecho antiquísimo sea necesario reconocer una pluralidad de concepciones superpuestas. El punto de partida principal (pero no único) está en la usucapión como integrativa de la originaria *mancipatio-venta*: aquí es necesaria una *mancipatio perfecta* en sí, salvo que el rito haya sido cumplido por el adquirente respecto de quien no era propietario de la cosa. Y quizá se requirió de *ab antiquo*, que en el acto de la *mancipatio* el adquirente ignorase el carácter de ajena de la cosa que adquiriría. A este caso se agregó pronto el de la *res Mancipi empti et tradita* (cfr. p. 207); y más tarde la jurisprudencia fué reconociendo otras hipótesis de usucapión, que respondían a las diversas circunstancias en las que una cosa puede ser mancipada, entregada, legada, adjudicada o de cualquier manera adquirida; en la lista se incluyeron también las hipótesis en las cuales la usucapión servía para transformar en propiedad civil una posesión atribuida por el pretor, como ocurre con la *missio in possessionem ex secundo decreto*, como conse-

³⁴ También aquí los papiros nos han conservado, en las actas de un proceso, un extracto del rescripto constantiniano. El texto ha sido publicado por C. J. KRAEMER y N. LEWIS, en *Transaction of the American philol. Assoc.*, 68, 1937, ps. 357 y ss.; cfr. ARANGIO-RUIZ, *Negotia*, n° 101, y *Parerga*, ps. 79 y ss.

³⁵ Cfr. en particular los estudios de BONFANTE, recogidos en *Scritti giur. varii*, II, ps. 469 y ss.; además PEROZZI, *Ist.*, 2ª ed., I, ps. 649 y ss.; GALGANO, *I limiti subiettivi dell'antica usucapio*, Napoli, 1913; COLLINET, *Mélanges Fournier*, 1929, ps. 71 y ss.

cuencia de la negativa a prestar la *cautio damni infecti* (p. 246). El elemento común a todos estos casos de usucapición fué visto en la convicción del usucapiente de no lesionar el derecho ajeno, a la que se llamó *bona fides*; por eso al *usus* conducente a la adquisición de la propiedad, que era referido bajo el concepto más reciente de posesión, se le llamó *possessio bonae fidei*.

La *possessio bonae fidei* o *ad usucapionem* fué protegida por el pretor también con aquella especie de reivindicación ficticia que es la *actio Publiciana*. Pero esta tutela valía contra todos, sin excepciones, solamente en el caso de que el defecto del título de adquisición estuviese en la forma, y que la cosa se hubiese recibido del verdadero propietario (caso de la propiedad pretoria, o *in bonis habere*, descrita en las ps. 207 y ss.); en cambio, si se había adquirido *a non domino*, con todos los requisitos exigidos para la usucapición, la *Publiciana* era eficaz frente al tercero simple poseedor, pero si hubiese sido intentada contra el verdadero propietario habría sido paralizada por la *exceptio iusti dominii*.

Otros casos de usucapición se han desarrollado sin la exigencia de la buena fe. Así ocurrió con la *usucapio pro herede*, que se iniciaba cuando alguien ocupaba, sin título, cosas pertenecientes a una herencia todavía no aceptada (cfr. cap. xxv, § 2). Y así también para los casos llamados de *usureceptio*, que tenían lugar cuando, en circunstancias determinadas, el ordenamiento jurídico facilitaba a ciertos enajenantes el retorno al goce de la cosa propia (la hipótesis más importante era la de la *fiducia*; cfr. cap. xvi, § 2, n° 2). Pero la divergencia de la regla general de la buena fe se fué atenuando también aquí.

Los requisitos de la usucapición y prescripción justinianeas (sustancialmente correspondientes, aparte de algunos aspectos particulares, al derecho clásico) fueron reunidos por los juristas medievales en el exámetro:

res habilis titulus fides possessio tempus.

Res habilis. Hay, en efecto, cosas no usucapibles. Tales, en todo tiempo, las cosas *extra commercium*; por la *lex Atinia* y por las leyes *Plautia* y *Iulia de vi*, las cosas furtivas y las cosas *vi possessae*, es decir, los muebles que fueron objeto de hurto o de robo y los inmuebles de que el poseedor fué violentamente despojado (*deiectus*); por la *lex Iulia repetundarum*, las cosas que el magistrado haya recibido en donación en la provincia que le fuera

asignada; en la época justiniana, las cosas del fisco, del príncipe, de los menores de edad, y las cosas dotales. No sólo le está prohibida la usucapión al primer poseedor (por ejemplo, al ladrón o despojante), lo que sería superfluo faltando el justo título y la buena fe, sino que pesa sobre la cosa un estigma que impide la usucapión por parte de todo sucesivo poseedor, aunque sea de buena fe; el vicio se purga, en la mayor parte de los casos, sólo con la *reversio ad dominum*, es decir, cuando la cosa vuelve a la posesión de su dueño.

Titulus o —como los romanos prefieren decir— *iusta causa usucapionis* es una situación jurídica objetiva que por sí misma justificaría la adquisición inmediata de la propiedad, pero que por insuficiencia formal del acto de transmisión o atribución (*traditio rei Mancipi* o acto discrecional del pretor), o bien por falta de derecho del transmitente (adquisición a *non domino*), vale solamente para iniciar la usucapión. Se distinguen varios tipos de los cuales bastará recordar los principales:

pro emptore (es el caso originario), cuando se haya comprado una cosa y después se haya hecho la *mancipatio* o la *traditio*, con uno u otro de los vicios recordados;

pro donato, cuando se haya hecho donación de la cosa sin haber contraído antes una especial obligación, y con vicios análogos;

pro dote, cuando, en las mismas condiciones, una cosa haya sido dada al marido por la esposa u otro, *ad onera matrimonii ferenda*;

pro legato, cuando haya sido objeto de un legado *per vindicationem*, siendo el testador solamente *possessor bonae fidei*;

pro soluto, cuando se la haya dado en cumplimiento de una obligación precedentemente contraída⁸⁶;

⁸⁶ En consecuencia, también, si hubiera sido transmitida por un heredero testamentario en ejecución de un legado ordenado por el testador en la forma *heres meus damnas esto dare* (legado *per damnationem*); también si, con fin de donación, alguien hubiera hecho una promesa jurídicamente obligatoria, que después cumple; también si alguno hubiera constituido la dote mediante *dictio* o *promissio dotis*, y, en consecuencia, cumpla su obligación. En este orden de ideas, también el título *pro emptore* habría debido fundirse con el título *pro soluto*, por ser igualmente la venta un contrato obligatorio que se cumple con la *mancipatio* o la *traditio*: permaneció separado, sea por la prevalecencia de esta causa de adquisición en la historia y en el funcionamiento de la institución, sea por el régimen especial, que pronto recordaremos, en cuanto a la buena fe.

pro derelicto, cuando alguien la haya recogido por haberla abandonado quien se comportaba respecto de ella como propietario (cfr. p. 211).

Para integración de los varios títulos hasta aquí indicados, la jurisprudencia admitió también un título *pro suo*. Su contenido es ambiguo, no sólo por las interpolaciones verificadas, sino también por las especulaciones doctrinales urdidas por los clásicos sobre el núcleo primitivo de la institución; de todos modos, parece que este título de usucapión se refiriese a casos en que la adquisición defectuosa lo era a título originario, como en la *missio ex secundo decreto* (p. 247) y en las hipótesis en que la *litis aestimatio* y la *adiudicatio* daban lugar a propiedad pretoria (p. 217, n. 18).

Hemos descrito las *iustae causae* desde el punto de vista de lo que se llama *título real*: en todos los ejemplos que hemos dado se tiene, en efecto, una verdadera venta, una verdadera donación, un verdadero pago, un verdadero abandono, etc., salvo que venta, donación, pago, abandono se han hecho *a non domino* o en forma insuficiente para la adquisición inmediata de la propiedad civil. Graves controversias suscitó, en cambio, en la misma jurisprudencia romana, el llamado *título putativo*, que se da cuando la venta, donación, pago, abandono, etc., existen sólo en la opinión del adquirente o, eventualmente, de ambas partes, en el sentido de que se ha hecho, por ejemplo, la tradición de la cosa sobre la base de un contrato de venta, de una obligación de *dare*, de un legado, etc., que no tenían existencia jurídica. La jurisprudencia romana se atiene, en su mayoría y en la mayor parte de los casos, a la exigencia de la realidad del título: pero no faltaron juristas más inclinados a admitir el título putativo, y en este orden de ideas se inspiró muchas veces también JUSTINIANO. La institución en la cual el título putativo parecería ser admitido sin reservas desde la época clásica es la *usucapio pro herede*, como modo de adquisición de las cosas hereditarias por parte del heredero aparente; pero más bien que de una reforma audaz en tutela de la usucapión, se trata del residuo de la antigua usucapión de la herencia, que no exigía un justo título (p. 235). Donde se admite el título putativo, se requiere que el error del usucapiente sea excusable (*probabilis, tolerabilis*).

Fides, o *bona fides*, es la convicción del usucapiente de no lesionar con su posesión el derecho ajeno. Tal convicción se identi-

fica, en la mayor parte de los casos, con la de haber adquirido desde *ab initio* la propiedad civil; pero esto no ocurre siempre, y en particular está excluida en ciertos casos del título *pro suo*. No es necesario que la buena fe persista por todo el tiempo necesario para la adquisición por usucapión o prescripción; basta que la haya en el momento inicial (*mala fides superveniens non nocet*). En quien haya de usucapir *pro emptore*, la buena fe se requiere en dos momentos, el de la conclusión del contrato y el de la mancipación o tradición; entre las varias explicaciones que se han dado, la más probable es que, partiendo de la *mancipatio* primitiva que resumía en sí, como hemos visto, la declaración de querer comprar y el actual tránsito de la propiedad, haya parecido oportuno que el requisito concurriese en ambos actos (contrato obligatorio y sucesivo acto de transferencia) en los que ordinariamente la *mancipatio* se descomponía. Mientras la prueba del título debe ser suministrada por el usucapiente, la buena fe se presume, y corresponde a la contraparte probar su falta.

Possessio es el señorío de hecho que el usucapiente ejerce sobre la cosa, sustitutivo en la terminología clásica del *usus* que en los orígenes daba nombre a la institución³⁷. Es una forma de posesión que se distingue de las otras con los nombres de *possessio ad usucapionem*, o *civilis*, o *bonae fidei*. La posesión debe ser ininterrumpida; la pérdida, aun momentánea, produce interrupción de la usucapión (*usurpatio*), y es necesario recomenzar desde el principio si eventualmente se recobra la posesión. Quien tenía un derecho que hacer valer contra el usucapiente de un fundo, podía interrumpir la posesión, al decir de Cicerón, arrancando una rama de una planta; pero si no se trata de un error, este gesto simbólico no fué ya reconocido en la época clásica. No bastaba para interrumpir la *possessio ad usucapionem* el ejercicio de la *rei vindicatio*; pero si el tiempo de la usucapión se cumplía entre la instauración de la *litis* (*litis contestatio*) y el pronunciamiento judicial, el juez debía igualmente ordenar al usucapiente demandado la restitución. En el derecho justiniano, en cambio, vale el principio (propio ya de la *praescriptio l. t.*) de que la iniciación de la *litis* interrumpe la posesión. En otros casos existe

³⁷ De la independencia originaria y recíproca del *usus* y de la *possessio* me voy siempre convenciendo más a través de la obra de mi sobresaliente alumna F. Bozza (de la cual véase especialmente las lecciones sobre *Possesso*, I, ps. 25 y ss.). Cfr. también LEIFER, loc. cit., p. 184, n° 1.

no ya interrupción, sino simple suspensión, es decir, se considera que por cierto período no corre el tiempo de la usucapión; esto sucede, en particular, por derecho justiniano, en el período en que el heredero del verdadero propietario, habiendo aceptado la herencia con beneficio de inventario; redacta dicho inventario.

Tempus es el período de tiempo requerido para la adquisición de la propiedad; hemos visto ya cuál es este tiempo en los distintos casos y en las diversas épocas. En caso de muerte del usucapiente, la posesión prosigue en el heredero (*successio possessionis*); en consecuencia, tampoco se requiere la buena fe del heredero porque en la idea de la posesión única su eventual mala fe sería *superveniens*. En cambio, el derecho clásico no admite que el adquirente a título particular, entre vivos (ejemplo: comprador) o *mortis causa* (legatario), pueda sumar con el tiempo de la propia posesión la del transmitente (*accessio possessionis*); esto se admitió, sin embargo, en edad avanzada para la *praescriptio longi temporis*, y en el derecho justiniano es principio general; pero desde el punto de vista de la buena o mala fe, se considera también el momento inicial de la posesión del causahabiente³⁸.

La *praescriptio longissimi temporis* continúa también en el derecho justiniano prescindiendo de la *iusta causa*; pero para que se pueda reivindicar el inmueble contra el antiguo titular que haya vuelto a poseerlo, o para que el adquirente de quien había prescrito pueda invocar la prescripción cumplida por su causante, es necesaria la buena fe inicial.

*
* *

En cuanto a la *pérdida de la propiedad*, poco queda que decir. Se pierde, en primer lugar, en todos los casos en que otro la adquiere; sea que nuestra pérdida funcione como causa de la adquisición de otro (como en las adquisiciones a título derivado), o que sea una simple consecuencia suya (como en la *litis aestimatio*, en la accesión, en la usucapión). Se pierde, además, por la destrucción de la cosa (*interitus rei*), a la cual, como hemos visto, se consi-

³⁸ Cfr. ZANZUCCHI, *La successio e l'accessio possessionis nell'usucapione*, en "Archivio Giuridico", 72, 1904, ps. 177 y ss., 343 y ss.

deraban equivalentes desde la época de los Severos algunos casos de especificación y de mezcla; se pierde cuando la cosa se pone fuera de comercio mediante *consecratio* o *publicatio*; se pierde con la *derelictio*, según la doctrina sabiniana que probablemente prevaleció; se pierde, en fin, cuando la cosa se transforma en sujeto de derecho, es decir, cuando un esclavo es manumitido.

§ 3. DEFENSA DE LA PROPIEDAD

Los diferentes modos de ataque y de defensa. — Las acciones petitorias: *rei vindicatio* y medios análogos; la *actio finium regundorum*. — Medios jurídicos de defensa contra las invasiones ajenas en la esfera de acción del propietario: *actio negatoria*, *a. aquae pluviae arcendae*, *cautio damni infecti*, *operis novi nunciatio*, *interdictum quod vi aut clam*. Medios dirigidos a garantizar la expansión de la propiedad *in alieno*: *int. de arboribus caedendis* y *de glande legenda*.

Los medios de defensa judicial y extrajudicial de la propiedad se pueden distinguir en varios grupos, según la naturaleza del ataque al que se contrapone la defensa.

Ante todo, la propiedad puede ser atacada en cuanto otro asuma frente a la cosa la posición de señor que el ordenamiento jurídico garantiza al propietario. Contra ataques semejantes, que despojan al propietario de la posesión, el medio principal es la *rei vindicatio*, en torno a la cual se pueden agrupar las acciones análogas en tutela de la propiedad provincial y pretoria, los diversos tipos de *rei vindicatio utilis* creados por el derecho justinianeo, y —en cierto sentido— la *actio finium regundorum*.

En segundo lugar, la propiedad puede ser atacada en cuanto, aun permaneciendo el propietario en posesión, otro desarrolle una actividad tal que aminore aquella plenitud de goce que el derecho le atribuye, u omita las precauciones necesarias para evitar daños. A estas formas de ataque se contraponen la *actio negatoria*, la *actio aquae pluviae arcendae*, la *cautio damni infecti*, la *operis novi nunciatio*, y el *interdictum quod vi aut clam*.

En fin, hay casos en que el pleno y exclusivo goce de la cosa hace necesaria cierta expansión de la propiedad fundiaria *in alieno*, con la correspondiente limitación de la propiedad de otro. Con-

tra la eventual oposición del propietario a quien se impone la limitación, se dan medios particulares: tales los *interdicta de arboribus cuedendis* y *de glande legenda*.

*
* * *

La acción fundamental en tutela de la propiedad, la *rei vindicatio*, ha sido recordada varias veces en el capítulo del proceso (ps. 129 y ss.; 140 y ss., y 173) y en otros lugares (ps. 217 y ss.).

En el antiguo proceso de propiedad, que se desarrolla en la forma de la *legis actio sacramenti in rem*, no se distinguen un actor y un demandado, uno de los cuales pretenda como suya la cosa que no tiene en posesión y el otro (poseedor) la defienda; por el contrario, ambos contendientes afirman la propiedad de la cosa diciendo: "*aio hanc rem meam esse ex iure Quiritium*". Después de esto, el litigio se concentra sobre el *sacramentum*, es decir, sobre la suma que cada una de las partes promete entregar a la caja pública en caso de ser vencida: juzgando "*utrius sacramentum iustum sit*", el juez elegido por las partes decide implícitamente la cuestión de propiedad. El problema más oscuro es el del modo en que el vencedor puede obtener satisfacción si la cosa se halla en poder del vencido y éste no la restituye conjuntamente con los frutos percibidos en el intervalo; la cosa no podía ciertamente, ser quitada por la fuerza al vencido, pero parece que era posible proceder ejecutivamente contra los *praedes litis et vindiciarum*³⁹.

No muy diferente debía ser el trámite del proceso *per sponsionem*, que parece haberse aplicado a la acción de propiedad, en época no muy antigua, cuando las partes mismas le daban la preferencia: éstas se prometían mutuamente una suma de dinero para el caso de que el adversario demostrase ser propietario de la cosa, y sobre tales promesas, del mismo modo que sobre el *sacramentum*, se trababa la *litis*⁴⁰.

³⁹ Cfr. ARANGIO-RUIZ, *Studi Mancaloni*, 1938, ps. 21 y ss.; WENGER, "Rev. Fundac. Savigny", 59, 1939, ps. 316 y ss.

⁴⁰ Sobre el tema, bastante misterioso, cfr. BOZZA, *Studi Bonfante*, 2, ps. 589 y ss.

Ya en la época ciceroniana la *rei vindicatio* está contenida en una fórmula condenatoria, y todo el procedimiento, desde el reconocimiento del derecho de propiedad hasta la reducción en dinero, se desarrolla ante un solo juez y según las prescripciones de una sola fórmula (véase en la p. 140). El proceso no es ahora doble sino simple: demandado es el poseedor, actor quien no poseyendo se dice propietario, y la carga de la prueba incumbe toda al actor⁴¹. En el caso de que el demandado no restituya voluntariamente, se suele proceder a la estimación de la cosa (*litis aestimatio*, ps. 156 y 217), mediante un *iusiurandum in litem* (juramento sobre el valor de la cosa controvertida) que el juez defiere al actor, y que evidentemente comprendía, en el uso práctico, aquel tanto en más del precio venal que debía servir para castigar convenientemente la obstinación del demandado y para indemnizar al actor por esta especie de expropiación forzosa.

También en el proceso de la época formularia, el demandado puede ser constreñido a dar garantía por el pago de la suma que fijará la condena (*cautio iudicatum solvi*); si se rehusa, la posesión de la cosa pasa al actor dispuesto a prestar la caución, con lo que el demandado se transforma en actor y queda sujeto a la carga de la prueba.

Solamente en el tipo más reciente de proceso (*cognitio extra ordinem*) se admite en materia de *rei vindicatio* el principio de

⁴¹ Además del poseedor, las fuentes dan como positivamente legitimados en la *rei vindicatio* a aquel *qui liti se optulit* (es decir, a quien, mientras habría podido desde el comienzo manifestar que la posesión no era suya, ha inducido en engaño al actor hasta la *litis contestatio*) y a aquel *qui dolo desit possidere* (es decir, a quien ha trasferido a otro su posesión precisamente para evitar la *vindicatio*). Ambos casos están comprendidos en la denominación de *ficta possessio*; en ambos, la restitución es imposible, y por eso la condena pecuniaria, que en la *vindicatio* normal debía representar un caso raro y estaba en todo caso fuera de la perspectiva del actor, habría sido aquí el único fin de la acción. Parece que ambos casos hubieran sido introducidos por Justiniano, mientras que en el derecho clásico la responsabilidad de quien *dolo desit possidere* se hacía valer con la *a. ad exhibendum* (personal) y la de quien *liti se optulit* a través de la *cautio iudicatum solvi*. Discutido es también el sentido en que se entiende, en la hipótesis normal, la exigencia de la posesión del demandado, es decir, si basta la mera detención o si es necesaria la posesión interdicial (cfr. para la distinción el cap. xi); la primera opinión parece que haya terminado por triunfar, con tal que, naturalmente, el retentor no estuviese en relación contractual con el actor mismo (cfr. particularmente SIEBER, por último, en *Römisches Recht*, p. 97).

la ejecución directa, *manu militari*, sobre la cosa, que la autoridad quita al demandado vencido y entrega al actor.

Ya en la época antigua, como hemos visto, el vencido que se hallaba interinamente en posesión debía restituir, además de la cosa, también los frutos percibidos durante el desarrollo del litigio (*lis et vindiciae*). También en el procedimiento *per formulam* el demandado, si no quiere sufrir la condena pecuniaria, debe restituir al actor los frutos percibidos después de la *litis contestatio*. Pero al poseedor de mala fe se le impone la obligación de restituir también los frutos percibidos *ante litem contestatam*, desde el momento en que entró en posesión de la cosa. En el derecho justinianeo se carga más aún la mano sobre él, fijando la obligación de la restitución no sólo de los frutos efectivamente percibidos, sino también de los *percipiendi*, es decir, de los que el poseedor de mala fe habría podido percibir disfrutando de la cosa más racionalmente. Por lo que se refiere al poseedor de buena fe, aparte de que para el tiempo posterior a la *litis contestatio* responde también él de los *fructus percipiendi*, JUSTINIANO le impone la restitución de los frutos antes percibidos y no consumidos (*exstantes*).

Mucho más incierta es la posición del poseedor de buena y de mala fe en los diversos estadios del desarrollo histórico, con respecto a los gastos realizados en relación a la cosa; sobre todo porque las indudables manipulaciones que los textos clásicos han sufrido en la compilación, hacen difícil establecer en qué parte los principios del derecho justinianeo correspondan al derecho clásico⁴². Ciertamente es que en la fórmula pura y simple de la *rei vindicatio* no hay lugar para gastos, con la sola excepción de los realizados para la producción de los frutos, los que son sustraídos de la estimación de los mismos frutos. En los otros casos de gastos necesarios o útiles, es decir, los realizados para la conservación de la cosa o tales que aumentan su valor, el derecho pretorio concedió al poseedor de buena fe una *exceptio doli*, con el resultado de que el propietario no recuperaba su cosa sino después de haberlos satisfecho (*ius retentionis* del demandado). Parece, en cambio, que no se podía invocar ningún remedio para los gastos vo-

⁴² Cfr. sobre el tema, RICCOBONO, *Dal diritto romano classico al diritto moderno*, en los "Annali del Semin. Giur. della Univ. di Palermo", vols. 3 y 4 (1917), especialmente en las ps. 357 y ss., 445 y ss.

luptuarios, es decir, de simple embellecimiento, y que en ningún caso pudiese el poseedor de mala fe pretender resarcimiento de gastos.

En el derecho justiniano, el resarcimiento se obtiene *officio iudicis*, considerándose que en cierto sentido los gastos se incorporan a la cosa disminuyendo la carga de la restitución. El derecho a la indemnización es extendido, para los gastos necesarios, también al poseedor de mala fe, y mientras sólo se concede indemnización al poseedor de buena fe por los gastos útiles (en la suma menor entre el gasto y la mejora), se le da en compensación no sólo a él sino también al poseedor de mala fe la facultad de retirar, en cuanto sea posible hacerlo sin dañar la cosa, las obras o construcciones que a ella se hubiesen agregado (*ius tollendi*). Esta facultad se concede también para las mejoras voluptuarias.

La *rei vindicatio* puede ser preparada por una *actio ad exhibendum*, sea en hipótesis particulares en que la cosa aparentemente haya perdido su individualidad (un ejemplo en la p. 213, n. 13), sea para verificar la identidad de la cosa poseída por otro con la que se quiere reivindicar. La misma acción puede intentarse para obtener que sea llevada *in ius*, y allí abandonada al actor la cosa por la cual el detentor no esté dispuesto a aceptar el proceso. Los límites de aplicabilidad de esta acción son, sin embargo, controvertidos.

Afines a la *rei vindicatio* son, como ya se ha señalado, las acciones que protegen la propiedad provincial y la propiedad pretoria. De la primera sabemos sólo que en los edictos de los gobernadores (por lo menos para las provincias senatoriales) tenía su puesto inmediatamente después de la *rei vindicatio*, bajo la rúbrica *si ager stipendiarius (vel tributarius?) petatur*; es probable que la fórmula correspondiese en general a la de la *vindicatio* normal, salvo que, en lugar de un *SI PARET FUNDUM CAPENATEM A^I A^I ESSE EX IURE QUIRITIVUM*, se habrá dicho *SI PARET SALTUM AFRICANUM QUO DE AGITUR AB A^O A^O POSSESSUM ESSE IURE STIPENDIARIO*, o análogamente. En cuanto a la acción en tutela de la propiedad pretoria (*a. Publiciana*), se ha visto ya que era ficticia, en cuanto el juez estaba obligado a proceder como si estuviese cumplido el plazo de la usucapión, tratando al actor como *dominus ex iure Quiritium*, siempre que concurriesen los otros requisitos de la usucapión. La fórmula la sacamos de GAYO, IV, 36: *SI QUEM HOMI-*

NEM A^{US} A^{US} EMIT ET IS EI TRADITUS EST⁴³ ANNO POSSEDISSET, TUM SI EUM HOMINEM, QUO DE AGITUR, EIUS EX IURE QUIRITIVM ESSE OPORTERET, NEQUE IS A N^O N^O A^O A^O RESTITUATUR, etc. (como en la *rei vindicatio*; cfr. p. 140).

A la reivindicación se parecen también, en el derecho justiniano, varias acciones concedidas en casos particulares y reunidas bajo el nombre de *rei vindicationes utiles*⁴⁴. La característica fundamental de las relaciones tuteladas por estas acciones, es la de ser no derechos reales, sino créditos ya defendidos como tales por acciones *in personam*, y caracterizados, sin embargo, además que por su objeto que consiste en la transmisión de una cosa en propiedad, por la facilidad de eludirlos transfiriendo la cosa a un tercero; es por esto que los bizantinos encuentran oportuno agregar a la *a. in personam* una *a. in rem*. Piénsese en la *lex commissoria* en virtud de la cual si el vendedor no recibe el precio de la cosa vendida, puede pretender su restitución. Para los clásicos, todo reside en establecer si la cosa ha pasado o no a propiedad del comprador; en la segunda hipótesis, cuando se verifica la condición, corresponde al vendedor la *rei vindicatio*, pero en la primera es necesaria una *actio in personam*, la *a. venditi*, a fin de que el demandado cumpla un nuevo acto de transmisión del dominio. JUSTINIANO conserva la *actio venditi*, pero da al vendedor también la *rei vindicatio utilis* contra cualquier poseedor: una prueba más de la debilitada conciencia de la distinción entre declaración contractual y acto traslativo de la propiedad, a la que se vinculan tantas otras innovaciones. Surge, pues, en el derecho justiniano, una figura mixta de derecho real y de obligación que se podría definir como obligación con eficacia real; los escritores medievales, y sobre todo los canonistas y los feudistas, que usaron ampliamente semejantes figuras para dar un colorido romanístico a la institución germánica de la investidura, crearon la categoría de los *iura in rem* o *ad rem*, distintos pero análogos a los *iura in re*.

⁴³ Así en la hipótesis que hemos visto ser la primera tomada en consideración para la concesión de la *Publiciana* (*res mancipi* vendida, luego trasferida mediante *traditio*). En los otros casos, la fórmula debe ser adaptada de distintos modos: por ej., "si quem hominem A^{US} A^{US} a L. Titio (el supuesto no dueño) emit mancipioque accepit", o bien "si quem hominem C. Seius iudex iudicio non legitimo A^O A^O adiudicavit", etc.

⁴⁴ Cfr. MANCALEONI, *Contributo alla storia e alla teoria della rei vindicatio utilis*, en *Studii sassaresi*, I. 1900.

En fin, debe colocarse sobre la misma línea de la rei vindictio, como bien lo vieron los jurisconsultos y los agrimensores romanos⁴⁵, el iudicium finium regundorum. La estructura originaria de esta acción es incierta; sólo se sabe que se desarrollaba en conexión con aquel limes de cinco pies dejado entre fundo y fundo según las reglas de la antigua limitatio (cfr. p. 201). Pero en la época clásica, caídas en desuso las controversias estrictamente relativas al limes, que los agrimensores llamaban de fine y de rigore, el juicio finium regundorum, debió intentarse solamente como controversia de loco, es decir, con el fin de establecer si determinada zona de terreno perteneciese a uno u otro de los dos fundos confinantes. Y aquí se trata, sustancialmente, de un juicio de propiedad, salvo que tiende a verificar no tanto la pertenencia como la extensión del derecho. El proceso remata en una adiudicatio; pero la adjudicación no es aquí, como en los juicios communi dividundo y familiae erciscundae, atributiva de nuevos derechos de propiedad (cfr. p. 217), sino —por lo menos normalmente— declarativa de derechos reconocidos como ya existentes.

Entre las defensas correspondientes a lo que hemos definido como el segundo tipo de ataques contra la propiedad, recordamos primero la *actio negatoria*, destinada a rechazar a quien se comporte respecto de nuestra cosa como titular de servidumbre o de usufructo. Pero sobre ella trataremos mejor en materia de derechos sobre la cosa de otro (*infra*, ps. 276 y ss.), conjuntamente con la acción que representa su antítesis, la *vindicatio servitutis* o *usufructus*.

En cambio, corresponde detenerse aquí sobre la *actio aquae pluviae arcendae*. En el derecho clásico ella tiende, como el mismo nombre lo pone de manifiesto, a hacer alejar el agua de lluvia cuando, por causa de canales cavados en un fundo superior, se desplaza violentamente o en excesiva abundancia sobre el fundo inferior, o cuando por medio de diques se hace refluir del fundo

⁴⁵ Cfr. especialmente D. 10, 1, 1, de Paulo: "*Finium regundorum actio [...] pro vindicatione rei est*" (donde las palabras intermedias, *in personam est licet*, están interpoladas).

inferior al superior; si antes de que se intente la acción, el fundo en cuya ventaja se hicieron las obras ha sido enajenado, se procede contra el nuevo propietario⁴⁶. En el derecho justinianeo la acción tiene un alcance mucho más vasto y tiende a regular la división de las aguas pluviales o surgentes entre vecinos, de modo que ninguno pueda consumir en menoscabo de los otros, más de lo que corresponda a las necesidades de su fundo; la acción puede ser ejercida, por ejemplo, si el propietario del fundo por el cual corre un torrente o nace una surgente hace desviar su curso en perjuicio de los vecinos, o si alguien, cavando en el propio fundo, corta el alimento de la fuente del vecino. Menos disímil de la función clásica es la competencia de la acción, si se ha formado naturalmente, en el fundo inferior, un dique que haga refluir el agua hacia el superior. Hemos visto (ps. 220 y ss.) cómo el espíritu que anima estas disposiciones ha ofrecido a los juristas medievales el punto de partida para la construcción de la teoría de los actos de emulación.

La *cautio damni infecti* es una promesa solemne, por la cual el propietario de un edificio que ofrece peligro, o que ejecuta sobre el fundo propio determinadas obras, se obliga hacia el vecino a resarcirle el daño que eventualmente derive para su edificio o terreno, por el derrumbamiento o por la nueva obra. Para obtener la promesa el interesado se dirige al pretor, quien, una vez comprobado mediante *causa cognitio* el fundamento de la petición, ordena la prestación de la *cautio*; cuando ésta se preste y, sucesivamente, se produzca el daño temido, el damnificado tendrá, para el cumplimiento de la promesa de resarcimiento que se le ha hecho, la *actio ex stipulatu*; en cambio, si el propietario del edificio que ofrece peligro, o el constructor de las obras, se rehusa a la prestación de la caución, se dispone en favor del interesado una *missio in possessionem*, sobre cuya base éste retiene, conjuntamente con el propietario, el inmueble del que teme pueda sobrevenirle perjuicio; y si el propietario se resiste también a

⁴⁶ Parece que derive de interpolaciones la distinción que en el Digesto se hace entre la posición del propietario que sea también autor de las obras, el cual está ciertamente obligado a restituir a sus expensas las cosas al estado primitivo, y la del sucesivo adquirente, que estaría solamente obligado a dejar entrar al vecino en el fundo para las necesarias demoliciones (*patientiam praestare*); cfr. BESELER, *Contributi*, III, ps. 93 y ss.

esta forma no leve de presión, se hace lugar, trascurrido un año, a una nueva *missio in possessionem* (*ex secundo decreto*) que constituye, como se ha visto, una *iusta causa usucapionis*, y muy probablemente uno de los casos en que la posesión de buena fe se eleva a la categoría de propiedad pretoria⁴⁷.

En cierto modo son análogos los medios de defensa conocidos bajo los nombres de *operis novi nunciatio* y de *interdictum quod vi aut clam*; no obstante su diversidad, los tratamos conjuntamente porque no resulta clara la distinción entre el campo de acción de ambas instituciones.

Cierto es que la *operis novi nunciatio* es un acto solemne extrajudicial, destinado a prohibir a alguien que prosiga una obra iniciada; no sabemos qué palabras pronunciaba el *nunciatus*, pero, por lo menos en ciertas regiones, las acompañaba con el lanzamiento de una piedra; tanto es así que el *iactus lapilli* se halla a menudo indicado sólo como una forma elemental y menos solemne de *nunciatio*, y así se conserva hasta el medievo.

El *nunciatus*, es decir, aquel contra quien se dirige la prohibición, puede solicitar la *remissio*, decreto del pretor que reconoce la inexistencia de un *ius prohibendi* y autoriza la prosecución de la obra; en cambio, si hace caso omiso de la prohibición y continúa la obra iniciada, el *nunciatus* puede impetrar del pretor un *interdictum demolitorium*. Parece, sin embargo, que dentro de cierto término el *nunciatus* debía realizar la demostración del derecho sobre cuya base había dispuesto la prohibición; faltando la demostración, estaría obligado a resarcir los daños causados a la contraparte.

El *interdictum quod vi aut clam* tiende también a la suspensión o remoción de obras ejecutadas ilícitamente. Ya sean realizadas *clam*, es decir en forma oculta, o *vi* (a despecho de la prohibición formulada por quien tenía facultad para ello). Ahora bien; si las obras realizadas *clam* no parecen tener relación alguna con las pasibles de *nunciatio*, el cotejo está en cambio muy pró-

⁴⁷ Tal la institución de la c. d. i. en el derecho clásico, y sustancialmente, salvo diferencias de detalle, también en el derecho justiniano. No sabemos, en cambio, todavía, que sea aquella *legis actio* que GAYO (IV, 31) dice corresponder en el caso de *damnum infectum* (para las varias conjeturas sobre el particular, véase BRANCA, *Danno temuto e danno da cose inanimate*, Padova, 1937, que ha dedicado a toda nuestra institución una investigación feliz y profunda).

ximo entre ésta y el interdicto, en su aplicación a las obras ejecutadas *vi*. Pero, ¿cuál es la relación entre los dos medios? De la *nunciatio* se ha dicho que compete ya sea *iuris publici*, o *iuris nostri tuendi gratia*; como ejemplo de derecho privado por ella tutelado, las fuentes señalan varias veces las servidumbres prediales, con lo que presuponen que las obras las ejecute el propietario del fundo sirviente en su fundo, sobre el cual corresponde a otros el derecho de servidumbre. De ello se ha deducido que la *operis novi nunciatio* es un medio destinado a impedir las obras que alguien realice sobre el propio fundo, causando daño de cualquier modo a otro, mientras que el *interdictum quod vi aut clam* correspondería en las obras realizadas sobre el fundo ajeno. Pero ésta es una mera posibilidad, y quizá es igualmente probable considerar que la *nunciatio*, acto solemne del derecho civil, encontrase aplicación únicamente cuando la obra violase una posición tutelada por el derecho civil mismo (por ejemplo, la servidumbre válidamente constituida, y en ventaja de un fundo del cual el denunciante fuese *dominus ex iure Quiritium*), mientras que el interdicto, medio de defensa puramente pretorio, tutelaría también situaciones de hecho provistas de protección por el pretor (por ejemplo, la *in bonis habere*, o directamente la simple *possessio*). La razón por la cual aun nos debatimos en la oscuridad es que JUSTINIANO, demasiado conservador de los antiguos esquemas para decidirse a cancelar instituciones que la antigüedad consagraba, tiende sin embargo a limitar fuertemente la aplicación de estos remedios y a transformarlos en acciones propiamente dichas; sobre todo, cuando exista su posibilidad, en acciones análogas a las *negatoriae servitutium*.

*
* *
*

Por lo que se refiere, en fin, a la defensa de la propiedad en la hipótesis en que su actuación requiere una limitada invasión de la esfera jurídica ajena, hay que tomar en consideración los *interdicta de arboribus caedendis* y *de glande legenda*.

El primero corresponde en dos casos:

1) Cuando los árboles de un fundo avanzan sobre el fundo vecino a una altura inferior a quince pies. Si el propietario del

árbol no corta las ramas bajas, el vecino tiene facultad de hacerse justicia por sí mismo, entrando también, llegado el caso, en el fundo confinante; si el propietario se opusiese, tendría lugar el interdicto.

2) Cuando los árboles de un edificio superior (plantados en jardines o, como comúnmente se usaba en la Italia antigua, también en las terrazas) avanzan sobre el edificio inferior. En esta hipótesis, todo el árbol debe ser cortado; la posición jurídica de las partes se regula como en el caso precedente.

El interdicto *de glande legenda* es el reglamento definitivo que el pretor ha dado de una institución contemplada ya por las XII Tablas. Estas disponían, en efecto, que si de un árbol que avanza (a la debida altura, se entiende) sobre el fundo del vecino caen frutos, el propietario del árbol tiene derecho de ir cada tres días (*tertio quoque die*) al fundo del vecino para recogerlos. El interdicto sirve, como en el caso precedente, para vencer cualquier oposición.

§ 4. EL CONDOMINIO⁴⁸

La regulación jurídica de la propiedad, tal como la hemos estudiado, presupone el estado normal, es decir, que la propiedad corresponda a una sola persona: una cosa, un propietario. Lo cual

⁴⁸ El tema es de los más trabajados en la literatura romanística, y de aquellos a los cuales los estudios de nuestros insignes investigadores han aportado, como resultado de disputas vivaces, óptimos resultados concretos. Me limito a recordar, para el concepto general de la institución, la admirable crítica de PEROZZI (*Saggio critico sulla teoria della comproprietà*, en "Il Filangieri", 15, 1890) y el artículo de BONFANTE en "Bull. Ist. Dir. Rom.", 25, ps. 196 y ss. (*Scr. giur.*, III, ps. 454 y ss.), cuyas conclusiones se asemejan bastante más de lo que a primera vista parece; para el régimen romano del *ius prohibendi*, otros estudios de los mismos autores (espec. BONFANTE, *Rend. Ist. Lomb.*, 46, 1913, ps. 665 y ss., y PEROZZI, *Mélanges Girard*, 1912, II, ps. 331 y ss.) y de RICCOBONO (en *Essays in legal history*, Oxford, 1913, ps. 33 y ss.); para la defensa de la posición de todos y de cada uno contra los ataques de extraños, REDENTI, *Pluralità di parti nel processo civile: diritto romano*, en el "Archivio Giuridico", 79, 1908, ps. 3 y ss.; para la *actio communi dividundo*, el libro de BERGER, *Zur Entwicklungsgeschichte der Teilungsklagen* [Sobre la evolución de los juicios divisorios], Weimar, 1912 (cuyos resultados sobre puntos particulares fueron nuevamente examinados, y en parte corregidos, por ALBERTARIO, por BIONDI y por mí), y por último FREZZA, "Riv. Ital. Sc. Giur.", nueva serie, 7, 1932, ps. 3 y ss. Una buena síntesis de toda la materia es la de GAUDEMET, *Étude sur le régime juridique de l'indivision*, Paris, 1934,

no cambia si, en un pensamiento jurídico avanzado, el titular de la propiedad es, antes que un particular, la ciudad o una comunidad menor o persona jurídica.

Pero mientras permanece inmutable el principio fundamental por el cual "*duorum in solidum dominium... esse non potest*" (D. 13, 6, 5 § 15), hay situaciones jurídicas en que el goce de la cosa, con exclusión de todo extraño, es garantizado no a uno sino a varios particulares en iguales o en diversas proporciones. Esto ocurre: para los bienes comprendidos en una herencia deferida a (o aceptada por) varios coherederos; para las cosas legadas, conjuntamente o por fracciones, a varias personas; para las cosas conferidas en sociedad; para las masas, ligas o mezclas resultantes de la confusión de cosas homogéneas o heterogéneas pertenecientes a distintos propietarios, y en otras hipótesis menos frecuentes. La situación que se determina de esta manera es conceptualmente transitoria, en el sentido de que cada uno de los copartícipes puede, en cualquier momento, pretender la división de la cosa, en los modos y con los efectos que examinaremos; pero nada impide que se prorrogue también durante mucho tiempo si ninguno de ellos ejerce tal facultad. De ahí la institución que llamamos condominio o copropiedad; a los romanos les es más familiar la denominación de *communio*, y a los copartícipes les dan a menudo el nombre de *socii*, aunque no raramente también el de *domini*.

Los problemas que se presentan al ordenamiento jurídico en esta materia son: organizar la defensa del condominio en el exterior, de modo equivalente, en sus efectos prácticos, a la defensa de la propiedad de sujeto único; repartir el goce de la cosa de modo que cada uno participe en él en la medida resultante del negocio o del hecho jurídico de que ha surgido el condominio; evitar todo perjuicio del interés de cada uno en la conservación de la actual estructura y destino de la cosa.

No parece que haya lugar para dudar que el condominio no sea más que un aspecto particular de la propiedad; pues, en efecto, la facultad del propietario de excluir de la cosa a todo extraño, que hemos visto era la característica esencial del dominio, vuelve a encontrarse aquí exactamente, y también vuelven a encontrarse todos los medios de defensa que competen al propietario contra terceros.

En lo referente a la medida del poder correspondiente a cada uno de los condóminos, resulta que la concepción romana no ha

permanecido inmutable desde la época primitiva al derecho clásico. El antiquísimo derecho conocía un *consortium* entre los hermanos que heredaban al padre y permanecían en el estado de indivisión; parecería, entonces, que el derecho de cada uno no se considerase correspondiente a una fracción determinada del fundo hereditario y de los otros bienes, sino como una cotitularidad solidaria del patrimonio (todos eran propietarios de todo). Cuando menos, la idea de la fracción (cuota hereditaria), que quizá ha funcionado en las relaciones internas del grupo para el reparto de los frutos y de los gastos, y ciertamente ha servido de norma para la eventual división, no entraba enteramente en juego en las relaciones con los extraños; aquí cada uno de los *consortes* personificaba al consorcio íntegro, tanto en los actos de disposición como en la defensa judicial. De manera que, por ejemplo, el esclavo perteneciente al *consortium* adquiría la libertad como consecuencia de la manumisión realizada aun por un solo condómino, y en forma análoga la *mancipatio* de una cosa perteneciente al patrimonio indiviso, con la intervención de uno de los condóminos, transmitía al *mancipio accipiens* la propiedad de toda la cosa⁴⁹. Debe admitirse, aunque no se halle atestiguado, que cualquier otro consorte, interviniendo oportunamente, podía impedir la manumisión o la *mancipatio*.

De esta reglamentación primitiva del condominio quedaba ya muy poco en la época clásica. Hasta donde es posible, los juristas romanos parten de la idea de *pars*; entendida esta expresión no en el sentido de parte material de la cosa (puesto que si cada uno fuese copropietario por una parte material, tal parte sería jurídicamente una cosa por sí, en propiedad exclusiva), sino en el sentido de una división ideal, por la cual sobre cada partícula de la cosa recae, en la proporción fijada, el derecho de cada uno: no *pars quanta*, sino *pars quota*, según la terminología medieval, o *cuota* como hoy se dice; de allí la definición de Q. Mucio SCE-

⁴⁹ Esto resulta hoy del excursus gayano sobre el *consortium*, que en el manuscrito veronés fué suprimido, pero que se ha vuelto a encontrar en los fragmentos de pergaminos egipcios (P. S. I., XI, 1182). Sobre los problemas relativos cfr. mi artículo en "Bull. Ist. Dir. Rom.", nueva serie, I, 1935, espec. ps. 601 y ss., y los autores allí citados: agréguese RABEL, *Erbengemeinschaft und Gewährleistung* [Comunidad hereditaria y prestación de garantía], en los *Studii Pappulias* (Μνημόσυνα Παππούλια); espec. ps. 192 y ss.; WIEACKER, *Societas*, I, Weimar, 1936, ps. 126 y ss.; LÉVY-BRUHL, *Nouvelles études* cit., ps. 51 y ss.

VOLA (D. 50, 16, 25 § 1), "*partis appellatione rem pro indiviso significari*". Este concepto de la cuota funciona, aparte de hacerlo en el momento de la división, también para todo cuanto se relaciona con la distribución de los frutos (naturales y civiles), de los gastos, de los daños eventuales. E igualmente funciona respecto de la transferencia del derecho de cada uno: yo transmito (por lo común, mediante *in iure cessio*) mi cuota de copropiedad, dejando invariada la situación jurídica de mis condóminos. Aun cuando la indivisibilidad del resultado jurídico a que el acto tiende no consiente la disposición parcial, la jurisprudencia clásica ha considerado extremadamente peligroso dejar al condómino como árbitro de la disposición total; a la manumisión de un esclavo se puede llegar sólo por vía indirecta, mediante sucesivas renunciaciones de los diferentes condóminos a las respectivas cuotas, hasta que el último que queda como propietario exclusivo manumite válidamente (cfr. p. 256, n. 52); en cuanto a la constitución de las servidumbres, se requiere la intervención de todos, y es discutible si los clásicos habrían consentido, como un texto interpolado lo haría creer, que el negocio constitutivo fuese concluido por los diversos condóminos en distinto tiempo.

Los problemas son análogos, pero no todas las soluciones coinciden, si de los actos de disposición se pasa a la defensa judicial del condominio. Ciertamente, así como enajeno mi cuota, así la reivindico: sea contra el tercero que goza de la cosa conjuntamente con mis verdaderos condóminos, sea contra los condóminos que me quieren excluir, sea contra el que a un tiempo me ha despojado a mí y a mis condóminos.

Se tiene así una *rei vindicatio partiaria*: normalmente *vindicatio certae* (*dimidiaae, tertiae*, etc.) *partis*, en cuanto por el título constitutivo conozca la fracción que me corresponde; pero eventualmente *incertae partis*, si por cualquier razón ignoro esta fracción (ejemplo en p. 216). Dada la independencia del derecho de cada uno que en la época clásica es la palabra de orden, pueden tenerse varios procesos de este género con relación a la misma cosa: si A y B la poseen como si fueran condóminos por mitades, yo, que pretendo ser copropietario por un tercio, intentaré la *vindicatio* por un sexto contra A y por un sexto contra B; si somos tres copropietarios por partes iguales y un extraño posee toda la cosa, cada uno de nosotros la reivindicará contra el poseedor por un tercio. Esta división de la controversia en tantos pro-

cesos distintos puede producir una diversidad de fallos, pero esto no puede causar preocupación desde el punto de vista jurídico, porque siempre es practicable un menor fraccionamiento de las cuotas; las partes, a quienes interesa evitar complicaciones, pueden intentar las distintas acciones en el mismo momento y ponerse de acuerdo acerca del nombramiento del mismo juez, el cual, por lo demás, tendrá que pronunciar tantas sentencias como sean las *vindicationes* parciales.

Pero hay otros casos en los cuales no se puede defender el derecho propio sin defender, simultáneamente, el de los condóminos. Típico es el de la servidumbre: que esté en condominio el fundo sirviente o el dominante, y que la acción se intente para el reconocimiento de la servidumbre (*vindicatio servitutis*) o para su desconocimiento (*actio negatoria*), el proceso no podría fundarse en la existencia de un cuarto o de un tercio de servidumbre, sino que debe siempre y necesariamente contemplarla en su totalidad. La acción es intentada, en consecuencia, por uno solo y contra uno solo, pero por el todo, *in solidum*; principio éste que se conforma al régimen de los actos de disposición en el *consortium* fraterno, por no haber sabido concebir los jurisconsultos una solución nueva. Pero puesto que (como se ha visto) a la doctrina evolucionada repugna que el acto de uno solo tenga efectos (eventualmente no deseables) para todos, la regla de la acción *in solidum* queda rodeada de todas las reservas posibles; si el demandado, antes de restituir la cosa al estado correspondiente a la situación jurídica declarada por el juez, prefiere pagar la *litis aestimatio*, ésta se paga en los límites de la fracción que mide los derechos del actor y del demandado sobre los dos fundos, salvo el ejercicio de acciones sucesivas para las restantes *aestimationes*.

Otras distinciones sutiles se establecen a propósito de la única servidumbre que impone al propietario del fundo una actividad positiva (*serv. oneris ferendi*), como también a propósito de las acciones que defienden contra los terceros la integridad del goce del fundo, como la *a. aquae pluviae arcendae*⁵⁰.

El principio según el cual cada uno obra aisladamente y como un propietario exclusivo, salvo la oposición eventual de los otros,

⁵⁰ Sobre todo esto cfr., además de REDENTI cit. en la p. 249, n. 48, también ARANGIO-RUIZ, "Bull. Ist. Dir. Rom.", 21, ps. 241 y ss.; GUARNERI-CITATI, *Obbligaz. indivis.*, 1, 1921, espec. ps. 56 y ss.; BESELER, "Rev. Fundac. Savigny", 46, ps. 92 y s. y 98; EIN, "Bull. Ist. Dir. Rom.", 39, ps. 203 y ss.

mantiene todavía su eficacia en época avanzada, para regular las innovaciones sobre la cosa común. En derecho clásico, este criterio encuentra su expresión en el *ius prohibendi*; él importa que cada condómino puede hacerse iniciador y ejecutor de una obra nueva, pero que cualquiera de entre los otros puede en todo momento oponer su veto, con el efecto no sólo de interrumpir la obra, sino también de imponer la destrucción de lo ya hecho. Es claro que la concepción del *ius prohibendi* responde al mismo criterio en que se inspira el ordenamiento de las magistraturas colegiadas romanas, y sobre todo de la de los cónsules, cada uno de los cuales puede realizar cualquier acto de gobierno, mientras la prosecución o ejecución no sea impedida por la *intercessio* del colega. Pero así como la práctica constitucional debió evitar los inconvenientes de este sistema, distribuyendo preventivamente los teatros de guerra entre los dos cónsules, o atribuyendo alternativamente a uno y a otro, mes por mes, o día por día, el comando supremo, así también cada condómino razonable debió abstenerse en la práctica de emprender cualquier obra sin haberse puesto previamente de acuerdo con los demás. Pues si bien se mira, esta necesidad era, en materia de condominio, mucho más manifiesta que en el ejercicio de los cargos públicos. El acto de gobierno remata, la mayoría de las veces, en algo irreparable: cuando un cónsul (en la época en que esto entraba en la esfera de la competencia consular) había declarado la guerra, ninguna *intercessio* podía impedir que hubiese guerra; si contra la propuesta de ley de uno de los cónsules el otro no había intercedido en tiempo oportuno, el arma de la *intercessio* se dirigía contra la ley ya votada, que no era más acto del magistrado sino de todo el pueblo. Pero contra el condómino que construía o demolía, la *prohibitio* no podía encontrar semejantes límites; en cualquier momento, quien había invertido en determinada obra tiempo y gastos podía ser paralizado y constreñido a destruir o a reedificar⁵¹.

⁵¹ Sobre la interpolación de aquella parte del D. 10, 3, 28, en que parece dicho lo contrario, ver RICCOBONO, loc. cit., p. 97. Es precisamente por esta razón que el régimen antiguo ha podido conservarse para las innovaciones mientras desaparecía de los actos de disposición: el condómino que construye y cava sin acuerdo preventivo está siempre expuesto a la sanción del *ius prohibendi*, mientras que si hubiese hecho tanto como manumitir al esclavo o constituir una servidumbre sobre el fundo, el daño sería irreparable.

En estas condiciones, el *ius prohibendi* no podía permanecer en vigor sino como criterio jurídico formal; prácticamente se le sustituye (y por cierto que desde la época clásica, si no ya en la republicana) el acuerdo preventivo. Es por eso que los textos nos presentan una especie de oscilación entre los dos criterios, los cuales no son inconciliables, pues mientras uno de ellos expresa más bien la concepción jurídica abstracta, el otro expresa el remedio con que se trató de evitar sus consecuencias desastrosas. Sólo en el derecho justiniano el principio del *ius prohibendi* se puede considerar definitivamente desaparecido; aquí el consentimiento unánime de los condóminos se ha convertido en el verdadero punto cardinal del sistema, como lo continúa siendo en el mundo moderno.

El régimen descrito se encuentra afirmado en nuestras fuentes exclusivamente para las innovaciones (construcciones, demoliciones, nuevas plantaciones en gran escala) y no para los actos de goce. Por lo que respecta, por ejemplo, a la siembra y a la cosecha de los frutos, está claramente dicho que cada condómino puede emprenderla, pero con la obligación de dividir con los otros los beneficios, y la obligación de éstos de dividir con él los gastos; y en cuanto a la locación, no sólo se admite que cada uno puede arrendar su parte, sino también alquilar *communi nomine* toda la cosa. El régimen presenta indudablemente puntos oscuros (y, ciertamente, el criterio de hacer vinculatorio para todos el parecer de la mayoría, que es fundamental en nuestro derecho para los actos de goce normal, no se presentó al pensamiento de los romanos sino en algún raro asomo del derecho justiniano); pero para resolver el problema práctico debió servir, por lo menos en la mayor parte de los casos, la regla que encontramos referida en D. 10, 3, 6 § 2: que el acto de gestión del condómino que actúa aisladamente sea vinculatorio también para los otros *si id demum gessit, sine quo partem suam recte administrare non potuit*.

Otro residuo de la primitiva concepción colectivista del condominio es la idea de la extensión potencial del derecho de cada condómino hasta abrazar toda la cosa, de modo que su división en cuotas sea solamente un efecto del concurso de los copartícipes, y que la cuota se haga *ipso facto* mayor, hasta restablecer la propiedad exclusiva, si los otros abandonan sus partes. De este fenómeno, conocido bajo el nombre de *ius adcrescendi*, tenemos un ejemplo típico: si el esclavo común es manumitido por uno de los condó-

minos, no se hace libre, pero se considera abandonado por el manumitente, y la cuota de éste recae en los otros condóminos⁵². Es indudable que el principio debía aplicarse en la época clásica, salvo la necesidad de la usucapión, también en los casos de abandono puro y simple (*derelictio*; cfr. p. 211)⁵³.

Hemos dicho que cada uno de los condóminos puede pedir en cualquier momento la división de la cosa; ésta puede tener lugar, por acuerdo entre las partes, mediante toda una serie de *in iure cessiones*, *mancipationes*, *traditiones* (por ejemplo, cedo *in iure* a mi condómino mi cuota de copropiedad sobre el fundo, e inmediatamente después él me cede una porción material del fundo mismo); pero la complicación de semejantes operaciones y el hecho de que no se hubiera ideado un medio jurídico especial para la división, prueban que se prefería proceder por las vías judiciales con la *actio* (o *iudicium*) especial *communi dividundo*. Es éste un *iudicium duplex* en el cual no se pueden distinguir uno o más actores, uno o más demandados; no hay en él, en efecto, controversia en torno a la pertenencia del derecho (si hubiese tal controversia se intentaría la *rei vindicatio partiaria*), sino sólo un conflicto de intereses sobre el mejor modo de traducir en derechos de propiedad exclusiva las diversas cuotas. Y en consecuencia, es un caso más bien de jurisdicción voluntaria que de jurisdicción contenciosa (cfr. ps. 133 y 141). El juez procede, como varias veces se ha dicho, a la *adiudicatio*: si la cosa es divisible, son normalmente adjudicatarios parciales todos los condóminos, cada uno por una porción material que responda en su valor a la cuota; si es indivisible, se le adjudica a uno (o eventualmente a más de uno, constituyendo un nuevo condominio con menor número de partícipes), y el adjudicatario es condenado a pagar a los demás sumas de compensación. El poder de condenar es reco-

⁵² Como se ha señalado en la p. 252, de este principio la jurisprudencia hizo aplicación al caso en que los condóminos estuviesen de acuerdo para manumitir al esclavo: si los condóminos son n , $n - 1$ manumisiones tienen solamente el efecto de hacer funcionar el *ius adcrendi*; pero la enésima, que es realizada por un propietario exclusivo, libera efectivamente al esclavo.

⁵³ Esto debía decir Ulpiano en el texto mal reproducido en D. 41, 7, 3, sea que se acepte la reconstrucción de RICCOBONO (*loc. cit.*, p. 59), sea que se considere, como con BONFANTE preferiría, que las palabras insignificantes "*ut hoc sit in parte quod in toto*", hayan sido sustituidas por los compiladores a la frase "*et socio adcrescit*" u otra semejante.

nocido al juez (aquí probablemente por obra de la jurisprudencia, sin cláusulas especiales en la fórmula) también para distribuir equitativamente entre los interesados los frutos, los gastos necesarios, los daños sufridos en razón de la cosa común o a ella causados ("si quid in his damni datum factumve est sive quid eo nomine aut abest alicui sociorum aut ad eum pervenit ex re communi": D. 10, 3, 3 pr.). En el derecho justinianeo, estas diversas pretensiones se consideran como una dirección particular de la acción *communi dividundo*, contrapuesta a su otra dirección que es la de la división; por eso se dice que la acción es *mixta, tam in rem quam in personam*: *in rem* en cuanto tiende a la división, *in personam* en cuanto tiende a las *praestationes*⁵⁴. Y partiendo de esta concepción se admite que la acción *communi dividundo* pueda intentarse también para las *praestationes* solamente, dejando todavía indivisa la cosa o haciendo valer pretensiones accesorias relativas a una cosa ya precedentemente dividida. En derecho clásico, estas pretensiones, cuando no se planteaban en ocasión de la división, se hacían valer con acciones especiales (por ejemplo, la *actio pro socio*, si la cosa había sido puesta en común con un contrato de sociedad, o la *actio negotiorum gestorum*, si uno de los condóminos había costado gastos en provecho común); solamente en el caso que alguno, luego de haber costado gastos o percibido frutos de la cosa común, hubiese después enajenado su cuota sin ajustar cuentas con los condóminos, se proveía, no pudiéndose intentar más la acción normal *communi dividundo*, con un *iudicium utile* modelado sobre ella, y basado, probablemente, sobre la ficción de que la enajenación no hubiese tenido lugar⁵⁵.

⁵⁴ Por derecho clásico, la acción no era ni *in rem* ni *in personam*, porque con ella ni se hace valer la propiedad o el derecho real que otro nos impugne, ni se obra contra alguien que haya contraído hacia nosotros una obligatio; en general, porque, como se ha dicho, no se trata de hacer valer un derecho, sino de resolver un conflicto de intereses.

⁵⁵ Sobre este último punto cfr. especialmente RICCOBONO, "Annali" cit., 3 y 4, 1917, ps. 170 y ss.

FRANJA MORADA

CAPÍTULO VIII

SERVIDUMBRES Y USUFRUCTO

§ 1. LA TERMINOLOGÍA JUSTINIANA DE LAS "SERVITUDES" Y LA DISTINCIÓN ENTRE SERVIDUMBRES PREDIALES Y PERSONALES

En el lenguaje jurídico corriente se suelen indicar todavía con el nombre común de servidumbres los más antiguos y difundidos derechos sobre la cosa ajena, tanto cuando están constituidos sobre un fundo y en ventaja de otro fundo (*servitutes praediorum* = servidumbres prediales), como cuando se constituyen sobre cualquier cosa corporal y en ventaja de una persona (*servitutes personarum* = servidumbres personales). Y ciertamente no podía hacer abandonar esta terminología el hecho de que no se hable de servidumbres personales en el Código Napoleón ni en el nuestro; la razón por la cual el Primer Cónsul fué contrario a la denominación de las *servitutes personelles* es, en efecto, totalmente retórica, puesto que le pareció que la expresión pudiese volver a traer a la memoria aquella servidumbre de la gleba que la Revolución había abolido. Pero uno de nuestros más insignes civilistas, VENEZIAN, observó ya que la amplia acepción de la palabra "servidumbre" abarca instituciones muy dispares entre sí, tanto en la estructura económica como en la regulación jurídica; y más tarde, LONGO demostró que esta terminología científicamente viciosa no es de los juristas romanos, sino de los justinianeos (cfr. p. 198).

Servidumbres (prediales) y usufructo no tienen en común más que la circunstancia de ser *iura in re aliena*. Como tales, estaban contemplados uno al lado de las otras en el Edicto pretorio y en las obras de los jurisconsultos, tenían modos análogos

de constitución y extinción, y análogos medios de defensa judicial. Es precisamente por esta consideración que tratamos de ellos en un solo capítulo, en el cual, después de haber descrito primero las servidumbres, y luego el usufructo y sus derivados, trataremos conjuntamente de los modos de adquisición y de extinción y de la defensa judicial.

Fuera de los aspectos indicados, no hay principios comunes al usufructo y a las servidumbres: es verdad que algunas reglas formuladas por los romanos en materia de servidumbres (*nemini res sua servit, servitus in faciendo consistere nequit*) podrían adaptarse también al usufructo, pero esto deriva de la característica de *iura in re aliena* que es común a aquéllas y a éste como a otras instituciones; por otra parte, mientras para las servidumbres esos principios merecen una especial mención, aplicados al usufructo se trasforman en verdades axiomáticas.

§ 2. LAS SERVIDUMBRES PREDIALES

Definición y principios comunes: tipos y paradigmas fundamentales.

Se llaman, pues, *servitutes*, según la correcta terminología romana, o también *iura praediorum*, los derechos constituídos sobre un fundo y en ventaja de otro fundo, en el sentido de que el goce del segundo (fundo dominante) aprovecha de una actividad que quien lo representa puede desplegar sobre el primero (fundo sirviente) o de una limitación que es impuesta al goce de éste. Esto quiere decir, en sustancia, que el propietario del fundo dominante tiene facultad de ejercer una actividad sobre el fundo sirviente o de exigir a su propietario una abstención; pero la característica de la servidumbre reside en que la relación jurídica no queda circunscrita a las personas de los actuales propietarios sino que se conserva inalterable para cuantas transferencias sufran los fundos de un propietario a otro. Tal característica distingue el derecho real de servidumbre de las obligaciones de idéntico contenido que pueden ser contractualmente convenidas entre los propietarios actuales; una obligación de este género vincula, en efecto, sólo a estos propietarios y sus herederos, pero cesa en caso

de transmisión a título particular; en cambio, la existencia de una servidumbre beneficia también al comprador o donatario del fundo dominante, y pesa igualmente sobre el comprador o donatario del fundo sirviente.

Siendo así, inescindible, activa y pasivamente, de la propiedad del fundo, la servidumbre es considerada por los jurisconsultos una cualidad de éste, "ut bonitas salubritas amplitudo" (cfr. Celso en D. 50, 16, 86). Y de esto derivan dos principios fundamentales. El primero, que la servidumbre debe ser constituida para una utilidad objetiva del fundo, no subjetiva de su actual propietario; así se puede hacer objeto de servidumbre el preparar la cal en el fundo vecino o recoger en él creta, pero solamente en cuanto la cal sirva para obras a construir en el fundo dominante o la creta para fabricar las tejas para la casa de campo y las vasijas para la conservación y el transporte del vino y del aceite; no podría, en cambio, ser objeto de derecho real sino solamente de obligación, la facultad de recoger creta para alimentar una fábrica de ladrillos, o la prohibición de ejercer cualquier industria en competencia con el propietario del fundo vecino. El segundo, que el fundo sirviente y el dominante sean vecinos: un requisito que no debe ser considerado en sí y por sí, sino en función del precedente. No es, en consecuencia, necesaria siempre la contigüidad, sino que basta una relación especial en virtud de la cual la servidumbre constituida sobre uno de los fundos pueda resultar ventajosa al otro; para una servidumbre de estilicidio, es necesario que el edificio de donde viene el agua y el patio que la recibe sean contiguos, pero también puede constituirse una servidumbre de pasaje si entre el fundo dominante y el sirviente hay una calle, y es también admisible todo un sistema de servidumbres de pasaje o de acueducto, mediante el cual el fundo dominante sea puesto en relación con una serie de fundos, desde el confinante hasta otros situados a distancia notable.

En cambio, no se requiere que la utilidad objetiva, para la cual la servidumbre se constituye, sea también perpetua. La existencia de un requisito especial, que se expresaba hablando de una *perpetua causa servitutium*, se solía deducir de D. 8, 2, 28; pero oportunamente se ha adelantado hoy la hipótesis de que la máxima se refiriese en derecho clásico solamente a las servidumbres urbanas, exigiendo que su goce se desarrollase sin el hecho del hom-

bre (lo que hoy se llamaría *continuidad*, en oposición a la *discontinuidad* de casi todas las servidumbres rústicas)¹.

En cuanto al principio *nemini res sua servit*, que encontramos tantas veces afirmado en nuestras fuentes, no es sustancialmente propio de las servidumbres, sino que expresa una regla general e intuitiva de los *iura in re aliena*; y ya veremos al estudiar los modos de extinción (p. 274), cuáles son sus consecuencias en nuestra materia.

La conducta que la existencia de la servidumbre impone al propietario del fundo sirviente es siempre negativa. Es verdad que se acostumbra distinguir entre servidumbres positivas y negativas; pero mientras el nombre de servidumbres negativas se da a las que prohíben al propietario del fundo sirviente ejercer algunas de las facultades normalmente comprendidas en el dominio (ejemplo, *s. altius non tollendi*, *ne luminibus officiatur*, etc.), positivas se dice de aquellas en virtud de las cuales el propietario del fundo dominante está autorizado para ejercer sobre el fundo sirviente cierta actividad (ejemplo: pasaje, acueducto, etc.). La distinción está, pues, mal establecida; para el propietario del fundo sirviente todas las servidumbres son negativas porque todas le imponen una abstención (de hacer lo que de otra manera podría hacer, o de prohibir lo que de otra manera prohibiría). Se suele expresar que ninguna puede imponerle una conducta positiva con la máxima, no romana, sino de los romanistas, *servitus in faciendo consistere nequit*. A esta regla se le reconoce, sin embargo, una excepción en la *s. oneris ferendi*, en virtud de la cual el fundo dominante se apoya en el muro o en la columna del fundo sirviente, y el propietario de éste se halla obligado a mantener en buen estado el sostén. La razón de la excepción reside, como se ha visto², en el hecho de que mientras el interés en la solidez del sostén es principalmente del edificio que en él se apoya, él pertenece, sin embargo, al edificio sirviente, y no se podría imponer al propietario del primero reconstruir a sus expensas la cosa de otro. Además, la actividad que así se impone

¹ BESELER, "Revue d'Histoire du Droit" (holand.), 1930, p. 224.

² SCIALOJA, en "Archivio Giuridico", 27, 1881, ps. 145 y ss. (= *Studi giuridici*, I, ps. 84 y ss.).

al propietario del fundo sirviente no representa el contenido esencial de la servidumbre, sino un detalle de su ejercicio; la obligación esencial es también aquí dejar que el vecino adose su construcción a nuestro muro o columna.

Los tipos más antiguos de servidumbre son los *iura itinerum* (servidumbres de pasaje) y el acueducto³. Entre los primeros es antiquísima la *via*, nacida quizá de la imitación de muy antiguas convenciones de carácter internacional ajustadas entre las distintas aldeas para permitir al ejército de una atravesar el territorio de otra, y transportada después a los *agri* ocupados por las vastas *possessiones* patricias; requiere una verdadera calle, cuya medida, relativamente bastante grande (normalmente 8 pies, 16 —si no hay un error de cálculo— en las curvas), está fijada, y su mantenimiento regulado por las XII Tablas. En época más avanzada, la jurisprudencia pontifical reguló la materia individualizando las dos servidumbres del *iter* y del *actus*, para comprender la primera la facultad de pasar a pie o a caballo, y la segunda la de conducir (*agere*) el ganado; la concomitante decadencia de la antiquísima *via* hizo que todos los formularios, en los actos constitutivos de la servidumbre y en la respectiva defensa judicial, usaran comprender en los nombres del *iter* y del *actus*, y en la endiadis* *ire agere*, toda servidumbre de pasaje, aunque el lenguaje vulgar continuara usando el viejo nombre de *via*. De ahí la construcción jurídica de ésta como suma del *iter* y del *actus*; construcción que entre los juristas clásicos es dominante, aun cuando en varias cuestiones prácticas no puedan menos que reconocer también al titular de un *actus* las modestas facultades comprendidas en el *iter*. JUSTINIANO corrigió esta parte del sistema describiendo las tres servidumbres como tres círculos concéntricos, de modo que el *actus* comprenda el *iter* y alguna cosa más, y la *via* comprenda el *actus* y alguna cosa más; pero ni aun en el derecho

³ Que fueron originariamente considerados como derechos de propiedad (o copropiedad), p. ej. sobre la zona por la cual se puede pasar o sobre la fuente o torrente, es tesis muy difundida; entre los más recientes véase ARU, "St. Econ. Giur. Univ. Cagliari", 24, 1936, ps. 403 y ss., y KASER, *Estudios en honor de P. Koschaker*, 1939, I, ps. 45 y ss.

* Figura verbal en la que se emplean innecesariamente, para expresar una sola cosa, dos palabras, una de las cuales es complemento de la otra. [N. del T.]

justinianeo está bien claro qué contiene de más la *via* con respecto al *actus*⁴.

A las servidumbres de pasaje y de acueducto, la práctica fué agregando muchas otras, sea en beneficio de los fundos rústicos, sea en servicio de los edificios, desde que éstos se multiplicaron en la ciudad. Fueron así nominativamente recordados por el Edicto, al lado del *ius eundi agendi* y del *ius aquae ducendae*, las servidumbres *altius non tollendi*, *oneris ferendi*, *tigni inmittendi*, *cloacae inmittendae*. Servidumbres típicas, a las cuales las fórmulas propuestas en el álbum pretorio señalaban, conforme al método de la jurisprudencia romana, las modalidades y los límites, pero que constituyen también los paradigmas según los cuales la práctica fué creando y los juristas reconociendo tantas otras servidumbres. Entre las que normalmente surgen para servicio de los fundos rústicos (*servitutes praediorum rusticorum*) recordaremos la *servitus aquae haustus* (que da el derecho de sacar agua), la *s. pecoris ad aquam appellendi* (facultad de conducir el ganado a abreviar en el fundo ajeno), y las ya mencionadas *servitutes calcis coquendae*, *cretae eximendae*, como también *harenae fodiendae*; entre las que normalmente surgen para servicio de los fundos urbanos (*servitutes praediorum urbanorum*) las servidumbres *stillicidii* y *fluminis* (dirigidas ambas a hacer caer en el patio vecino el agua de lluvia), *proiciendi* y *protegendii* (que conceden la facultad de hacer sobresalir balcones o aleros), *ne prospectui officiat*, *ne luminibus officiat*. La posibilidad de servidumbres de este género, dentro de los límites de los principios generales ya expuestos, es indefinida; sólo así puede explicarse cómo todavía entre los juristas de la época de los Severos se pudiese discutir, con relación al requisito de la utilidad objetiva del fundo dominante, acerca de la licitud de esta o de aquella servidumbre particular, y cómo de conformidad con las soluciones preferidas se adaptaran los paradigmas de acciones y de interdictos que estaban indicados en el Edicto.

⁴ Contra estas conclusiones de mi estudio *Per la classificaz. delle servitù di passaggio* (Studi Brugi, 1910, p. 247) no me parece persuasiva la investigación de MEYLAN, Studi Albertoni, I, 1934, ps. 95 y ss. Más cerca mío, aunque divergente en cuanto a la procedencia histórica de la *via*, SOLAZZI, *Specie ed estinzione delle servitù prediali*, Napoli, 1948, ps. 27 y ss. (el vol., como el otro de 1947, *Requisiti e modi di costituzioni delle s. p.*, es precioso para la materia de este parágrafo; así también el curso de BIONDI, *La s. p. in dir. rom.*, Milano, 1946).

Las cuatro servidumbres más antiguas, y con ellas —consecuentemente— todo el grupo de las servidumbres rústicas como tales, fueron incluidas en la categoría de las *res Mancipi*. Son, en cambio, *nec Mancipi* las urbanas. Las consecuencias se verán a propósito de los modos de adquisición.

§ 3. EL USUFRUCTO Y LOS DERECHOS ANÁLOGOS

Principios fundamentales del usufructo. — Cuasi usufructo, uso, *fructus sine usus*. La *habitatio* y las *operae servorum*.

El usufructo es el derecho de usar de la cosa ajena y de percibir sus frutos, dejando intacta su estructura y su destino económico ("*ius alienis rebus utendi fruendi, salva rerum substantia*")⁵. En algunas decisiones que se apoyan sobre todo en la autoridad de JULIANO, el usufructo es considerado y definido como *pars rei*, casi como si su constitución representase una división (cualitativa, ver p. 199) del dominio; pero no parece que de esta definición se hayan desprendido consecuencias de relieve, debiendo excluirse especialmente que los juristas romanos se hayan representado al usufructo como un poder que pueda corresponder indiferentemente a persona distinta del propietario (usufructo formal) o al propietario mismo (usufructo causal); esta doctrina surgió solamente en la Edad Media⁶. Para los romanos el usufructo ha sido siempre un derecho sobre la cosa ajena, que se extingue si el usufructuario adquiere la propiedad de la cosa; su desarrollo jurídico, en los modos de adquisición y de extinción y en la defensa judicial, está elaborado a imitación del de las servidumbres, primogénitas entre los *iura in re aliena*.

Frente al *usufructuarius*, el dueño de la cosa toma el nombre de *dominus proprietatis*, o de *propriarius* (palabra que no ha tenido nunca entre los romanos el significado más genérico que nosotros le damos). Conserva la facultad de disponer de la cosa, enajenándola de cualquier modo, pero debe evitar todo acto que

⁵ D. 7, 1, 1. PEROZZI y PAMPALONI juzgan que el inciso final fué interpolado; no comprendo por qué DI MARZO, *Studi Fadda*, 1, 139 y ss., hace a la definición críticas todavía más radicales.

⁶ Intentó resucitarla PAMPALONI, *Il concetto classico dell'usufrutto*, en "Bull. Ist. Dir. Rom.", 22, 1910, ps. 109 y ss.

pueda disminuir el goce del usufructuario; no puede, por ejemplo, constituir sobre el fundo, servidumbres tales que disminuyan su utilidad actual (por ejemplo, pasaje, acueducto, etc.), pero puede, en cambio, constituir de aquellas que lo comprometan a dejar el fundo en el estado actual, como la *s. altius non tollendi*.

El usufructo surge (según parece, en la época republicana) con aquella función alimentaria que ha conservado sustancialmente siempre. De ahí sus principios fundamentales: a) conexión inescindible con la actual estructura y destino económico de la cosa; b) conexión igualmente inescindible con la persona y con la actual situación jurídica (*status*) del usufructuario; c) temporaneidad.

a) Por el primero de los principios enunciados queda, ante todo, excluido que el usufructuario pueda, de cualquier manera, cambiar la estructura y el destino actual de la cosa, aun cuando de ello resultase una mejora (Riccobono); no puede, en consecuencia, transformar una viña en olivar ni un campo de agricultura en otro de pastoreo, ni cavar minas, ni construir edificios o demolerlos, ni cambiar las funciones de los esclavos en la economía familiar. Menos aún podría realizar actos de disposición, como la constitución de servidumbres sobre o en favor del fundo; le faltaría, para hacerlo, la representación del fundo, que conserva el propietario. También si una modificación esencial de la estructura de la cosa sucede sin (y hasta contra) la voluntad del usufructuario, el principio encuentra aplicación; si el edificio cae, el derecho del usufructuario no se traslada sobre el área edificable; si el fundo recibe incremento por una isla nacida en el río, sobre este incremento no se extiende su poder.

El mismo derecho sobre los frutos es, en cierto modo, concebido por los romanos como una derivación del derecho preferente que corresponde al propietario; de ahí la regla ya examinada (p. 218), por la cual, mientras con la separación natural de la cosa fructífera el fruto es adquirido por el propietario, el usufructuario sólo lo adquiere con la percepción. Aparte de esto, corresponde al usufructuario toda especie de fruto, natural y civil. Un problema algo complejo es el de las adquisiciones del *servus fructuarius*, en conexión con el principio de que normalmente toda adquisición del esclavo corresponde al amo que lo tiene en potestad; aquí se consideran correspondientes al usufructuario las adquisiciones que el esclavo hace *ex re fructuarii* (es decir, con dinero o con otras

cosas suyas o especulando con el peculio por él constituido), o bien *ex operis suis* (es decir, arrendando a otro los propios servicios); en cambio, si el esclavo, por ejemplo, es instituido heredero o beneficiado con legados, la adquisición es del *propriarius*.

Para la conservación de la cosa y su restitución al vencimiento del término, el usufructuario puede ser obligado a prestar al propietario una caución llamada *cautio usufructuaria*. La misma caución sirve para garantizar la obligación que incumbe al usufructuario de costear los gastos ordinarios, es decir, los que deben hacerse periódicamente para el goce y la conservación de la cosa.

La obligación de conservación de la sustancia importa que sólo puedan ser objeto de usufructo las cosas susceptibles de uso repetido (no consumibles). Era frecuente, sin embargo, desde la época republicana, que por testamento se dejase a determinada persona el usufructo de todo el patrimonio o de una fracción de éste, sin distinguir entre cosas consumibles y no consumibles; y la costumbre se hizo todavía más frecuente a principios del Imperio, cuando las leyes matrimoniales de AUGUSTO (cfr. cap. XXI, § 1), limitando la capacidad de los célibes y cónyuges *sin prole* para recibir por testamento, la redujeron en ciertos casos al usufructo de una cuota del patrimonio; en estos casos, la ulterior limitación a las cosas no consumibles habría representado una grave exageración. Para evitarlo, un *senadoconsulto*, dictado probablemente bajo Tiberio, admitió que con respecto a las cosas consumibles se pudiese llevar a la práctica, mediante su entrega al legatario seguida de una *cautio especial*, un régimen económicamente análogo al del usufructo; no siendo posible un goce continuado con subsiguiente restitución, las cosas consumibles se hacían propiedad de aquel a quien se dejaban en usufructo, y éste restituía al vencimiento otras tantas del mismo género y calidad. Tal es la institución que los justinianos llamaron *cuasi usufructo*⁷.

En el derecho justiniano el mismo régimen fué extendido, como ya se vió (p. 184), a los vestidos, con derogación inelegante

⁷ Cfr. GROSSO, *Sul quasi-usufrutto*, en "Bull. Ist. Dir. Rom.", 32, 1936, ps. 237 y ss. En cuanto a la acción a intentarse por el legatario contra el heredero, y salvo el caso frecuente de que el usufructo se refiriese a una cuota del patrimonio, diré que, si el legado había sido hecho *per damnationem*, correspondía la *a. ex testamento* normal; en cambio, si el usufructo de las cosas fungibles hubiese sido legado *per vindicationem* (forma ciertamente inoportuna), convengo con GROSSO sobre la necesidad de una *utilis vindicatio ususfructus*.

de la distinción entre cosas consumibles y no consumibles, pero con exacta valoración práctica; se estableció también que estuviese en facultad del cuasi usufructuario restituirla, antes que el *tantundem eiusdem generis*, el valor en dinero.

De cualquier modo, es claro que esta institución no tiene con el usufructo nada de común desde el punto de vista jurídico; la posición del cuasi usufructuario coincide más bien con la de un mutuario. Tanto es así que, ya sobre la base de la caución, ya sobre la hipótesis de que el heredero haya omitido requerirla, la acción otorgada contra el titular y sus herederos después del término del cuasi usufructo no es *in rem* sino *in personam*, es decir, según los casos, la *actio certae creditae pecuniae* o la *condictio certae rei*, las mismas acciones que tutelan el mutuo de dinero o de mercancías.

b) El segundo de los principios enunciados (conexión del usufructo con la persona y con la actual situación jurídica del usufructuario) importa ante todo la intrasmisibilidad del usufructo, es decir, que el usufructuario no pueda investir a otra persona del derecho real que le corresponde. Es verdad que las fuentes admiten, además de la *locatio*, la *venditio ususfructus*; pero esta venta, que no es seguida por ningún acto de transmisión o constitución del derecho real, tiene por única consecuencia que el cesionario se sustituya al titular en el ejercicio; el único que puede reivindicar el usufructo, que responde frente al *dominus*, es el usufructuario designado en el acto constitutivo, y es su muerte la que determina la extinción del derecho.

Otra consecuencia del mismo principio es que el usufructo se extingue con la *capitis deminutio*, es decir, con el cambio del *status*; la regla encuentra en la época clásica frecuente aplicación en los cambios del *status familiae* (*cap. deminutio minima*). Puede evitarse la consecuencia incluyendo en el legado de usufructo una cláusula con la cual se determina que el derecho se reconstituye cuantas veces cese por la causa indicada (*ususfructus repetitus*): tal cláusula, que es una condición, no podría, en cambio, estar contenida en la *in iure cessio* o *mancipatio, actus legitimi* que no toleran elementos accidentales (p. 97). El derecho justiniano reduce la regla a los mínimos términos, limitándola a las *capitis deminutiones maxima* y *media*, pérdida de la libertad y de la ciudadanía (C. 3, 33, 16, §§ 2 y 3).

c) En fin, el principio de la temporaneidad importa que el usufructo, cuando no se fije otro término, cese con la vida del usufructuario. Sin embargo, si un usufructo es dejado por testamento a varias personas sin distribución de partes, no sólo la fracción que a cada uno corresponde en el primer momento está determinada por el número de los aceptantes (de manera que, si de dos legatarios uno renuncia, el otro tiene todo el usufructo), sino que también, si posteriormente uno de los cusufructuarios muere o de otra manera pierde su derecho, su porción acrece a los otros, en lugar de consolidarse con la propiedad. Una hipótesis delicada es la del usufructo constituido, sin fijar término, en favor de una persona jurídica (por ejemplo, de un *municipium*). En textos de juristas también de época relativamente avanzada, como PAPINIANO, la dificultad es orillada contemplando la eventualidad de que el usufructo se extinga por falta de uso; pero esto no resuelve la cuestión, porque el no uso es un fenómeno excepcional, que trasformaría en normal la perpetuidad. En dos pasajes de la compilación justinianeas, atribuidos ambos a GAYO (D. 7, 1, 56; 33, 2, 8), se fija el término de cien años, *finis vitae longaeui hominis*; pero la contradicción patente que hay entre estos textos y los otros ha sido satisfactoriamente explicada considerando que ellos están interpolados*.

Derivados del derecho de usufructo, y sus atenuaciones, son el *usus*, el *fructus sine usus*, y en el derecho justiniano la *habitatio* y las *operae servorum*.

El *usus*, en su significado originario, es el derecho de usar de una cosa sin percibir sus frutos; debió normalmente ser propio de las cosas no fructíferas, y ser además concebido como exclusivo de cualquier fruto civil; así, se habrá constituido un derecho de uso sobre una biblioteca o un esclavo, y constituyéndolo sobre una

* Cfr. FADDA, *Il limite di tempo all'usufrutto delle persone giuridiche*, en "Atti R. Acc. di Napoli", 34, 1902; *Conc. fondam. del dir. ered.*, I, ps. 181 y ss. El hecho de que los dos textos sean ambos de GAYO, y de que su motivo fundamental vuelva a encontrarse en otro pasaje gayano (D. 7, 1, 3, § 2), hace sospechar que las manipulaciones demostradas por FADDA se remontan hasta aquellos maestros bizantinos que antes de JUSTINIANO tomaban las obras de GAYO como base de su enseñanza. DI MARZO. "Bull. Ist. Dir. Rom.", 14, ps. 122 y ss., considera que los textos están más gravemente deformados, y que en el origen declararan incapaces de usufructo a las personas jurídicas.